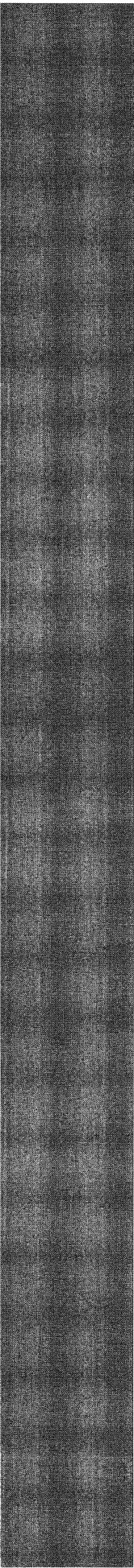


민사집행 실무제요
집행총론

제1편

총론

- 제1장 민사집행법 개요
- 제2장 민사집행의 의의와 종류
- 제3장 민사집행의 집행기관
- 제4장 민사집행 전자소송
- 제5장 민사집행에서의 불복방법
- 제6장 집행비용
- 제7장 집행에 관한 담보·보증·공탁



제1장 민사집행법 개요

1. 민사집행법의 제정 연혁

1960. 4. 4. 법률 제547호로 제정된 민사소송법은 제7편 강제집행편에서 제1장 총칙, 제2장 금전채권에 관한 강제집행, 제3장 금전채권 외의 채권에 대한 강제집행, 제4장 가압류와 가처분에 관한 규정을 두고 있었다.

1990. 1. 13. 법률 제4201호로 민사소송법 제7편 강제집행편 내에 ‘제5장 담보권의 실행 등을 위한 경매’에 관한 규정을 신설함으로써 집행권원 없이 이루어지는 담보권 실행을 위한 경매절차를 강제집행편에 편입하는 한편 종래 이 절차에 적용되던 경매법을 폐지하였다.

1990년의 개정 이후, 포괄적인 내용을 가진 강제집행편이 재판절차를 중심으로 한 민사소송법의 일부로 되어 있는 것은 체계상 맞지 않는다는 비판이 있고, 집행절차를 민사소송법에서 분리하여 단행법으로 제정하는 것이 세계적 추세이며, 소송절차와 집행절차는 그 기본 이상, 성격, 절차상의 원칙 등을 달리하고 담당기관이 분리되어 절차의 진행이 독립적으로 이루어지며 불복방법을 달리하는 등으로 하나의 법률로 규율하기에 적절하지 않다는 이유에서, 2002. 1. 26. 법률 제6627호에 의하여 민사소송법 중 집행절차에 관한 규정을 따로 떼어 별도로 민사집행법을 제정하기에 이르렀다.

2. 민사집행법의 편제

민사집행법의 편제는 다음과 같다. 강제집행, 담보권 실행 등을 위한 경매와 보전처분의 절차로 크게 나뉜다.

- 제1편 총칙
- 제2편 강제집행

제1장 총칙

제2장 금전채권에 기초한 강제집행

제1절 재산명시절차 등

제2절 부동산에 대한 강제집행

제1관 통칙

제2관 강제경매

제3관 강제관리

제3절 선박 등에 대한 강제집행

제4절 동산에 대한 강제집행

제1관 통칙

제2관 유체동산에 대한 강제집행

제3관 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행

제4관 배당절차

제3장 금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행

제3편 담보권 실행 등을 위한 경매

제4편 보전처분

3. 총칙

제1편 총칙(1조 ~ 23조)에서는 종전의 민사소송법 강제집행편 총칙의 조항 중 강제집행, 담보권 실행을 위한 경매, 민법·상법 그 밖의 법률의 규정에 의한 경매 및 보전처분의 절차에 공통적으로 적용될 수 있는 조항을 모아 배열하였다.

다만 보전처분절차는 소송절차와 집행절차의 양면을 포괄하고 있어서 집행절차에 관한 총칙의 규정들을 소송절차를 포함한 보전처분절차에 그대로 적용할 수는 없기 때문에 민사집행법 1조는 강제집행, 담보권 실행을 위한 경매, 민법·상법 그 밖의 법률의 규정에 의한 경매만을 협의의 “민사집행”으로 정의하고 있다.

- 5 민사집행법을 제정하면서 목적(1조), 집행관에 대한 원조 요구(7조), 외국송달의 특례(13조), 주소 등이 바뀐 경우의 신고의무(14조), 시·군법원의 관할에 대한 특례(22조), 민사소송법의 준용 등(23조) 규정을 신설하고, 즉시항고(15조)와 집행에 관한 이의신청(16조) 제도를 대폭 정비하였다.

4. 강제집행

제2편(24조 ~ 263조)은 강제집행절차를 규정하고 있다.

그 중 제1장 총칙(24조 ~ 60조)은 각종의 강제집행절차에 공통적으로 적용되는 규정을 모아 두고 있는데, 총칙편의 주요 개정사항으로는 채무명이라는 용어를 집행권원으로 변경한 것(56조), 원칙적으로 확정된 지급명령은 집행문을 부여받을 필요 없이 강제집행을 할 수 있도록 변경한 것(58조), 집행문부여 등에 관한 이의신청제도를 정비한 것(34조)과 민사집행법상의 특별대리인에 대하여 민사소송법의 관련 조항을 준용하는 규정을 신설한 것(52조 3항)이 있다.

제2장(61조 ~ 256조)은 금전채권에 기초한 강제집행절차를 규정하고 있다.

제1절은 재산명시절차, 채무불이행자명부 등재절차, 재산조회절차 등을 규정하고 있는데, 명시기일 불출석 등의 경우에 채무자를 20일 이내의 감치에 처할 수 있도록 한 규정(68조)과 재산조회절차(74조 ~ 77조)가 신설되었다.

제2절은 부동산에 대한 강제집행절차를 규정하고 있는데, 가장 모범적인 절차이고 그 규정을 다른 강제집행절차에 준용할 필요가 있으므로 종전과 달리 앞으로 편제하였다. 제1관 통칙에는 부동산에 대한 강제집행방법을 강제경매와 강제관리로 한다는 규정(78조)과 집행법원의 관할에 관한 규정(79조)을 두고, 강제경매절차는 제2관(80조 ~ 162조)에서, 강제관리절차는 제3관(163조 ~ 171조)에서 각각 규정하고 있다. 미등기 건물에 대한 집행방법을 마련하고(81조, 82조, 85조 2항), 배당요구의 종기에 관한 규정을 정비하였으며(84조, 87조 3항 ~ 5항), 경매부동산에 존재하는 용익권의 소멸과 인수에 관한 규정을 신설하고(91조 3, 4항), 매수신고 후에 변제증서 또는 채무유예증서가 제출된 경우 최고가매수신고인 등이 동의하면 강제집행이 정지되도록 하였으며(93조 3항), 일괄매각제도를 확대하고(98조 ~ 101조), 매각방법을 호가경매, 기일입찰, 기간입찰 중에서 집행법원이 정하도록 하였으며(103조), 매각허가에 대한 이의신청사유(121조)와 매각허가여부에 대한 항고제도(130조 ~ 132조) 등을 정비하였다.

제3절은 선박에 대한 강제집행절차(172조 ~ 186조)를 규정하고, 자동차·건설기계·소형선박(자동차 등 특정동산 저당법 3조 2호에 따른 소형선박을 말한다) 및 항공기(자동차 등 특정동산 저당법 3조 4호에 따른 항공기 및 경량항공기를 말한다)에 관한 강제집행절차는 대법원규칙에 위임하고 있다(187조).

제4절은 동산에 대한 강제집행절차를 규정하고 있는데, 제1관 통칙에는 집행방법과 압류의 범위에 관한 규정(188조)을 두고, 유체동산에 대한 강제집행절차는 제2관(189조 ~

222조)에서, 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행절차는 제3관(223조 ~ 251조)에서, 배당절차는 제4관(252조 ~ 256조)에서 각각 규정하고 있다.

제3장(257조 ~ 263조)은 금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행절차를 규정하고 있다.

5. 담보권 실행 등을 위한 경매

제3편(264조 ~ 275조)은 담보권 실행 등을 위한 경매절차를 규정하고 있다. 즉, 이곳에서는 저당권·질권 등의 담보권 실행을 위한 경매절차와 유치권에 의한 경매절차 및 민법·상법 그 밖의 법률이 규정하는 바에 따른 경매(이른바 형식적 경매)절차를 규정하고 있다. 강제집행편의 총칙 규정인 42조 내지 44조 및 46조 내지 53조의 규정을 준용(275조)하는 한편 대체로 담보권 실행을 위한 경매절차는 담보목적물의 종류에 따라 같은 종류의 물건에 대한 강제경매절차에 준하여 정하고, 유치권에 의한 경매와 형식적 경매는 담보권 실행을 위한 경매의 예에 따라 실시하도록 정하고 있다.

6. 보전처분

제4편(276조 ~ 312조)은 보전처분의 재판절차와 집행절차를 규정하고 있다.

제2장 민사집행의 의의와 종류

제1절 민사집행의 의의

민사집행법이 규율하고 있는 강제집행, 담보권 실행을 위한 경매, 민법·상법 그 밖의 법률의 규정에 의한 경매 및 보전처분을 광의의 민사집행이라고 할 수 있고, 위 절차 중 보전처분을 제외한 절차, 즉 강제집행, 담보권 실행을 위한 경매, 민법·상법 그 밖의 법률 규정에 의한 경매를 협의의 민사집행이라고 할 수 있다(민집 1조). 보전처분절차는 보전명령을 얻기 위한 보전소송절차와 그 보전명령을 집행하기 위한 보전집행절차의 두 가지로 구성되어 있어서 협의의 민사집행절차와 구분되지만, 그 중 보전집행절차에는 강제집행절차를 준용하기 때문에 민사집행법에서 함께 규정하고 있다.

민사집행법이 민사집행이라는 용어를 사용하고 있는 곳은 2조, 4조, 7조 1항, 8조 2항, 18조 1항, 23조, 108조 4호인데, 문리해석상 보전집행절차를 제외한 협의의 민사집행을 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이다. 반면 민사집행법은 여러 곳에서 집행절차라는 용어를 사용하고 있는데, 총칙편에 사용된 집행절차라는 용어(3조, 13조, 15조, 16조, 17조 등)는 원칙적으로 보전집행절차를 포함하는 것으로 해석된다.

제2절 강제집행

1. 강제집행의 의의

강제집행은 채권자의 신청에 의하여 국가의 집행기관이 채권자를 위하여 집행권원에 표시된 사법(私法)상의 이행청구권을 국가권력에 기하여 강제적으로 실현하는 법적 절차

이다. 이를 나누어 설명하면 다음과 같다.

(1) 강제집행에 의하여 실현되는 것은 사법상의 청구권이다. 사법상의 청구권에는 채권적 청구권뿐만 아니라 물권적 청구권이나 신분권·인격권 등의 권리 침해에 기한 회복, 예방 등을 구하는 청구권도 포함되고, 그 내용은 작위, 부작위를 가리지 않는다.

여기서 말하는 강제집행은 사법상 청구권의 실현을 목적으로 하는 점에서 공법상 청구권의 실현을 목적으로 하는 행정상의 강제집행과 다르고, 집행권원을 요건으로 하는 점에서 담보권 실행을 위한 경매와 구별된다.

(2) 강제집행의 대상이 되는 것은 이행청구권에 한한다. 확인판결이나 형성판결은 그 확정으로 기판력이나 형성력이 발생하여 판결을 구한 목적이 달성되므로, 새삼스럽게 강제집행을 할 필요가 생기지 않는다.

(3) 강제집행에는 강제력이 따른다. 즉, 강제집행은 채무자의 의사에 구애받지 아니하고 강제력을 행사하여 의무내용을 실현하거나 또는 특정의 방법을 사용하여 채무자에게 심리적 압박을 가함으로써 채무자로 하여금 부득이 협력하게 하여 의무내용을 실현하게 하는 것이다.

한편 국가의 강제력을 사용함이 없이 재판에 기하여 그 내용에 적합한 일정 상태를 실현할 수 있는 경우가 있다. 예를 들어, 등기절차의 이행을 명하는 확정판결에 기한 단독 신청에 따라 등기관이 등기기록에 등기사항을 기록하는 것(민집 263조, 부등 23조 4항), 친생자관계부존재확인의 확정판결에 기하여 가족관계등록부를 정정하는 것(가등 107조), 회사
9 설립무효확인의 확정판결에 기하여 수소법원이 등기의 촉탁을 하는 것(비송 98조), 강제집행의 기본이 되는 재판을 취소하는 재판 또는 강제집행을 허가하지 아니하거나 그 정지를 명하는 재판에 기하여 집행기관이 집행의 정지·취소를 하는 것(민집 49조, 50조) 등인데, 이는 특별규정에 따라 해당 재판의 반사적 효력으로 행하여지는 것에 불과하고 국가의 강제력 행사에 의한 이행청구권 실현과는 관계가 없으므로, 여기에서 말하는 강제집행에는 해당하지 않는다.

다만 이러한 것도 재판에 기한 국가의 행위라는 점에서는 유사하므로 이를 광의의 강제집행이라고 하고, 이에 대응하여 여기에서 말하는 강제집행을 협의의(또는 본래의) 강제집행이라 한다.

(4) 벌금·과료·몰수·추징 등 재산형이나 과태료는 검사의 명령에 의하여 집행하고 검사의 이러한 집행명령은 집행력 있는 집행권원과 동일한 효력이 있으며 이에 관하여는 민사집행법의 규정이 적용 또는 준용된다(민집 60조, 질서 42조, 비송 249조, 형소 477조).

이처럼 공법상 청구권의 집행을 강제집행에 의하도록 하는 것은 편의상 강제집행제도를 이용하는 경우에 불과하므로 이를 형식적 강제집행이라 한다.

(5) 강제집행은 채권자의 신청에 따라 행하여진다.

이행청구권의 사실적 형성을 현실적으로 실시하는 강제집행권은 국가에 있으나, 채권자가 그 권리의 실현을 바라지 않는데도 국가가 직권으로 채무자를 강제하여 그 의무를 이행하도록 할 수는 없고 채권자의 신청이 있을 때 비로소 개시된다.

(6) 강제집행은 국가기관에 의하여 권리를 실현한다는 점에서 사적 집행과 구별된다. 강제집행이 국가기관에 의하여 행하여지도록 한 것은 집행절차의 적정, 타당성을 확보하기 위해서이다. 그러므로 집행의 요건, 방법, 효과 등은 법규에 의하여 확일적으로 정하여지고, 이를 임의로 변경하는 것은 명문으로 인정되는 것 이외에는 허용되지 않는다(임의집행의 금지). 임의집행의 금지라고 하는 구속은 당사자는 물론 집행기관에 대하여도 가하여진다. 임의집행의 금지에 관하여는 특히 집행계약과의 관계가 문제 됨을 주의할 필요가 있다.

(7) 강제집행절차가 민사소송절차인지 비송사건절차인지에 관하여는 다툼이 있다. 즉, 10 법의 판단 그 자체를 목적으로 하여 당사자의 권리확정주장에 대하여 판단하는 작용이 소송사건이고 실체권의 존재 또는 실체상의 법률요건을 전제로 하여 행하여지는 작용이 비송사건인데 강제집행절차는 확정된 권리의 실현을 위한 것이므로 비송사건의 범주에 속하는 것으로 보아야 한다는 견해와 강제집행도 판결절차와 더불어 일종의 소송절차의 형태로서 행하여지는 법률적 절차라고 하는 견해가 있다.

2. 강제집행절차와 판결절차의 관계

(1) 판결절차는 권리 또는 법률관계 존부의 확정, 즉 청구권 존부의 관념적 형성을 목적으로 하는 절차이고, 강제집행절차는 권리의 강제적 실현, 즉 청구권의 사실적 형성을 목적으로 하는 절차이다.

양자는 밀접한 관계에 있기는 하지만, 전자에서는 그 성질상 공평·신중한 심리가 요청됨에 반하여 후자에서는 정확·신속한 실현과 채권자의 이익보호가 요청되기 때문에 양자는 별개의 기관(수소법원이 집행기관이 되는 것은 예외적이다. 민집 260조, 261조)이 관장하는 독립된 절차이고 후자가 전자의 속행도 그 일부도 아니다.

(2) 모든 강제집행에 판결절차가 반드시 선행하는 것은 아니다. 공정증서, 조정조서(민

조 29조, 가소 59조), 과태료의 재판에 관한 검사의 명령(민집 60조) 등에 의하여도 강제집행을 할 수 있다.

(3) 모든 소송이 강제집행을 수반하는 것은 아니다. 확인판결이나 형성판결은 소송비용의 재판 부분을 제외하고는 집행력이 없으므로 그 외의 부분은 강제집행으로 이행하지 아니하고, 이행판결 중에 성질상 강제집행에 적합하지 아니한 것(예를 들어, 부부의 동거를 명하는 판결)과 강제집행의 필요가 없는 것(예를 들어, 채무자가 임의로 의무를 이행한 경우, 등기 절차를 명하는 판결)도 있다.

(4) 강제집행절차는 판결절차와 병행하여 진행될 수도 있다. 가집행의 선고가 있는 종국판결(민집 24조)에 의하여 그 확정 전에 강제집행이 행하여지는 경우가 이에 해당한다.

- 11 (5) 강제집행은 판결절차 또는 이에 갈음하는 관념적 형성절차를 전제로 하나, 집행을 계기로 하여 다시 판결절차가 발생하는 경우가 있다. 예를 들어, 청구이의의 소(민집 44조), 제3자이의의 소(민집 48조) 등이 이에 해당한다.

3. 강제집행의 종류

가. 집행의 대상을 기준으로 한 분류

(1) 인적집행과 물적집행

집행의 대상이 물건이나 사람이냐에 의한 구별이다. 물적집행(대물집행)은 채무자의 재산만을 집행의 대상으로 하는 것이고, 인적집행(대인집행)은 채무자의 재산뿐만 아니라 그 신체나 노동력을 집행의 대상으로 하여 이에 의하여 채권의 만족을 얻는 집행이다.

민사집행법은 일반적으로 사법(私法)상의 채무에 대한 인적집행을 인정하지 아니하지만, 예외적으로 재산명시명령을 위반하여 재산명시기일에 불출석하거나 재산목록의 제출 또는 선서를 거부한 때에는 20일 이내의 감치에 처하도록 함으로써(민집 68조 1항) 인적집행을 허용하고 있다.

(2) 개별집행과 일반집행

물적집행의 대상이 되는 채무자의 재산의 범위에 따른 구별이다.

개별집행은 채무자의 개개 재산에 대하여 집행이 개별적으로 실시되는 것이며, 일반집행은 채무자의 전 재산에 대하여 포괄적으로 실시되는 집행이다. 전자는 민사집행법이 채용하고 있는 방법이고 후자는 파산절차에서 행하여진다.

(3) 동산집행과 부동산집행

집행의 대상이 되는 채무자의 재산의 종류에 따른 구별로서 우리 민사집행법의 편제는 이 분류에 의하고 있다.

대상재산의 종류에 따라 집행기관, 집행절차 등에 여러 가지 차이가 있다.

민사집행법상의 동산에는 민법상의 그것과 달리 유체동산뿐만 아니라 채권과 그 밖의 재산권도 포함된다. 한편 선박, 자동차·건설기계·소형선박, 항공기는 민법에서는 동산이지만, 민사집행법에서는 등기할 수 있는 선박이나 등록된 자동차, 건설기계 및 ‘자동차 등 특정동산 저당법’의 적용을 받는 소형선박·항공기·경량항공기는 부동산에 준하여 취급된다(민집 172조, 187조, 민집규 106조, 108조, 130조).

12

제1편
제2장
제2절

나. 집행방법을 기준으로 한 분류

(1) 직접강제, 대체집행, 간접강제

집행에 사용되는 강제수단에 따른 구별이다.

직접강제는 채무자의 협력 없이 집행기관의 행위에 의하여 직접 권리의 내용을 실현하는 집행방법을 말하는데, 금전채권이나 그 밖의 물적 급부를 목적으로 하는 청구권(물건의 인도 등)의 집행에 적합하다. 채무자의 신체나 의사에 압박을 가하지 않고 실시되기 때문에 강제수단으로서는 가장 타당한 방법이고 현행법상의 원칙적인 집행방법이다.

대체집행은 채무자로부터 비용을 추심하여 이로써 채권자 또는 제3자로 하여금 채무자를 대신하여 의무내용을 실현하게 하는 집행방법이다. 집행기관이 직접 실시하는 것은 적합하지 아니하나, 채무자 자신에게 시키지 아니하더라도 채권자에게 동일한 만족을 줄 수 있는 대체적 작위의무(건물철거 등)의 집행에 적합한 방법이다(민집 260조).

간접강제는 채무자에 대하여 배상금의 지급을 명하거나 벌금을 과하거나 또는 채무자를 구금하는 등의 방법에 의하여 심리적 압박을 가함으로써 채무자로 하여금 스스로 채무를 이행하게 하는 집행방법인데, 현행법에서는 벌금이나 구금 등에 의한 강제는 인정되지 않고 배상금의 지급만이 인정된다(민집 261조 1항). 채무자 자신의 행위에 의하지 않으면 목적을 달성할 수 없는 부대체적 작위의무와 부작위의무의 집행방법으로 적합하다(예를 들어, 재산관리의 청산을 할 의무, 소음을 발생시키지 말아야 할 의무 등).

13

(2) 본래적 집행과 대상적 집행

본래적 집행(원물집행)은 실체적 청구권의 내용, 즉 채권자에게 귀속할 급부내용을 그대로

로 실현하는 집행방법이다.

대상적 집행(금전집행)은 청구권의 종류·내용에 불구하고 반드시 금전급부의 형식으로 전환하여 실현하는 집행방법이다.

민사집행법은 본래적 집행을 원칙으로 하나, 파산절차에서는 모든 재산적 청구권을 금전채권으로 변환하여 집행하기 때문에(채무자회생 426조, 427조) 대상적 집행의 실질을 띠고 있다.

대체집행이나 간접강제는 엄밀한 의미에서의 본래적 집행은 아니고 그것과 대상적 집행을 병용하고 있는 것이라고 할 수 있다.

다. 집행의 효력을 기준으로 한 분류

(1) 본집행과 가집행

본집행은 채권자에게 종국적 만족을 주는 집행이고, 가집행은 채권자에게 가정적, 잠정적 만족을 주는 데 불과한 집행으로서 상급심에서 가집행의 선고 또는 본안판결을 바꾸는 판결이 선고되면 바뀌는 한도에서 그 효력을 잃는다(민소 215조 1항).

다만 본집행이나 가집행이나 모두 집행절차로서는 청구권에 대한 최종적 만족의 단계에까지 나아간다는 점(만족집행)에서 차이가 없고, 이 점에서 보전집행과 다르다.

(2) 만족집행과 보전집행

- 14 청구권을 강제적으로 실현하여 최종적 만족의 단계에까지 나아가는 집행을 만족집행이라 하고, 장래에 할 만족집행을 위하여 현상을 보전하는 것을 목적으로 하는 집행을 보전집행이라 한다.

현행법상 보전집행에는 장래의 집행을 보전하기 위한 것과 현재의 위험방지 등을 목적으로 하는 것이 있다.

전자로는 가압류 및 다툼의 대상에 관한 가처분이 있고, 후자로는 임시의 지위를 정하기 위한 가처분이 있다. 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 집행의 보전과는 직접 관련이 없으나 분쟁으로 인하여 당사자에게 생길 현재의 위험이나 불안을 제거·방지하기 위하여 그 해결 시까지 권리관계를 잠정적으로 형성하는 것으로서, 주식회사의 이사선임결의취소 등을 본안으로 하는 이사에 대한 직무집행정지 및 대행자선임 가처분, 인도단행가처분 등이 있다. 이는 일종의 민사행정적인 처분이고 본래 의미의 강제집행에 속하는 것은 아니나 다툼의 대상에 관한 가처분과 유사하기 때문에 같은 절차 안에 두고 있다.

라. 실현될 권리를 기준으로 한 분류(금전집행과 비금전집행)

실현될 권리가 금전채권인 경우의 집행을 금전채권에 기초한 집행(금전집행)이라 하고, 금전채권 외의 채권인 경우의 집행을 금전채권 외의 채권에 기초한 집행(비금전집행)이라 한다.

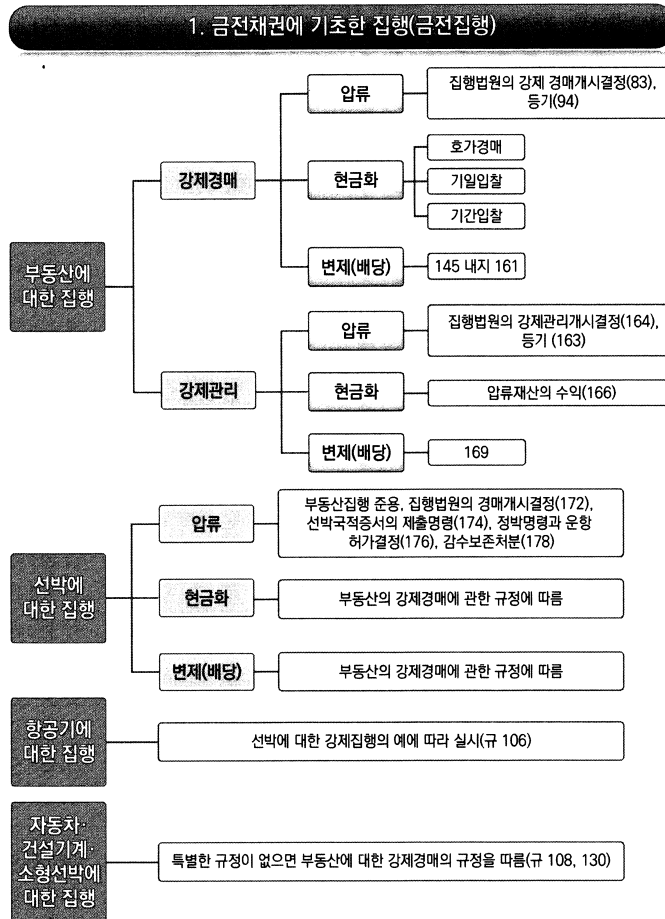
민사집행법은 양자를 명백히 구별하여 규정하고 있고 이 구별은 절대적이며 이를 무시하여 일방의 규정을 타방에 적용하는 것은 허용되지 않는다.

금전집행은 금전채권의 만족에 충당되는 집행대상재산의 종류에 따라 부동산에 대한 집행, 선박 등에 대한 집행, 동산에 대한 집행으로 구분되고, 선박 등에 대한 집행은 선박에 대한 집행과 자동차·건설기계·소형선박 및 항공기에 대한 집행으로 세분되며, 동산에 대한 집행은 다시 유체동산에 대한 집행(유체동산집행), 채권과 그 밖의 재산권에 대한 집행(채권집행, 권리집행)으로 구분된다.

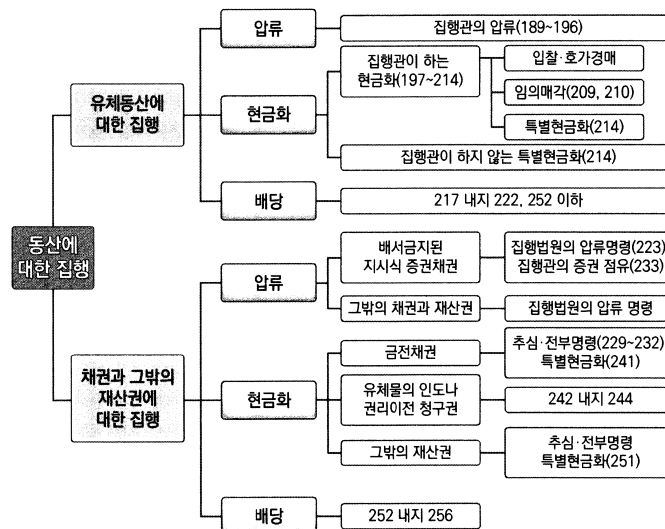
비금전집행은 물건의 인도를 구하는 청구권의 집행과 작위(대체적·부대체적 작위), 부작위, 의사표시를 구하는 청구권의 집행으로 나뉜다.

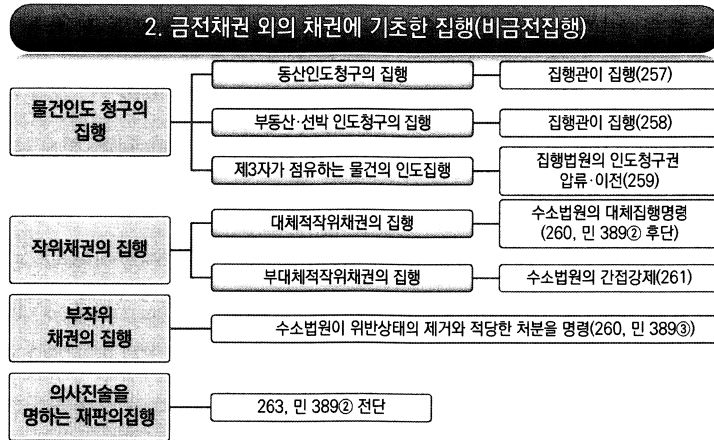
15

[강제집행의 도해]



16





제3절 담보권 실행 등을 위한 경매

17

1. 의의

민사집행법 제3편(264조 ~ 275조)은 담보권 실행 등을 위한 경매에 관하여 규정하고 있는데, 그 실행에 집행권원이 필요하지 않은 이러한 경매를 통틀어 강제경매에 대응하는 개념으로 임의경매라고 부른다. 이 중 저당권, 질권, 전세권 등의 담보권 실행을 위한 경매는 채권자가 자기 채권의 만족을 얻기 위하여 실행한다는 점에서 강제경매와 공통점을 가지므로 강제경매와 담보권 실행을 위한 경매를 실질적 경매라고 부르고, 이에 대응하여 재산의 가격보전 또는 정리를 위한 경매를 형식적 경매라고 부른다.

한편 유치권은 이른바 법정담보물권으로서, 유치권자는 채권을 변제받기 위하여 경매를 신청할 권리를 갖지만(민 322조 1항), 담보물권의 가장 중요한 속성인 우선변제권을 갖지 않으므로 질권이나 저당권 같은 전형적인 담보물권과는 다른 점이 있다. 이 때문에 구 경매법은 유치권에 의한 경매를 담보권 실행을 위한 경매절차에 따라 실시하도록 하였으나, 1990년 개정 민사소송법은 유치권에 의한 경매를 형식적 경매절차에 따라 실시하도록 변경하였고, 민사집행법도 이를 따르고 있다(민집 274조 참조). 이러한 이유에서 민법·상법 그 밖의 법률 규정에 의한 현금화를 위한 경매를 협의의 형식적 경매라고 하고, 이것과 유치권에 의한 경매를 합쳐서 광의의 형식적 경매라고 한다.

2. 담보권 실행을 위한 경매의 종류

- 민사집행법은 담보권 실행을 위한 경매를 목적물의 종류에 따라 ① 부동산을 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매(민집 264조 ~ 268조), ② 선박을 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매(민집 269조), ③ 자동차·건설기계·소형선박(자동차 등 특정동산 저당법 3조 2호에 따른 소형선박을 말한다) 및 항공기(자동차 등 특정동산 저당법 3조 4호에 따른 항공기 및 경량항공기를 말한다)를 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매(민집 270조), ④ 유체동산을 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매(민집 271조, 272조), ⑤ 채권과 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매(민집 273조)로 구분하고 있다.

3. 형식적 경매의 종류

민사집행법이 협의의 형식적 경매와 유치권에 의한 경매를 같은 경매절차에 따라 실시하도록 규정하고 있음은 위에서 설명한 바와 같다.

유치권에는 민사유치권(민 320조)과 상사유치권이 있고, 상사유치권에는 대리상의 유치권(상 91조), 상인 간의 유치권(상 58조), 위탁매매인의 유치권(상 111조, 91조), 준위탁매매인의 유치권(상 113조, 111조, 91조), 운송주선인의 유치권(상 120조), 운송인의 유치권(상 147조, 120조), 선장의 유치권(상 807조 2항) 등이 있다. 상사유치권은 그 취지와 목적이 민사유치권과 다른 점이 많아 입법론으로는 형식적 경매의 일종으로 취급할 것이 아니라 법정질권으로 파악하여 담보권 실행을 위한 경매의 일종으로 취급하는 것이 타당하다는 주장이 있으나 현행법은 그와 같은 구별을 하고 있지 않다.

형식적 경매의 종류는 다음과 같다.

- ① 공유물 분할을 위한 경매 : 현물분할이 어려운 경우 공유물 분할을 위한 경매(민 269조 2항), 소유권 이외의 재산권 공유의 경우 분할을 위한 경매(민 278조, 269조), 상속재산의 분할을 위한 경매(민 1013조 2항)가 있다.
- ② 자조매각 : 특정물의 인도 의무를 부담하는 사람이 그 인도 의무를 면하기 위하여 물건을 금전으로 현금화하는 것을 목적으로 경매를 신청하는 경우를 일반적으로 자조매각(自助賣却)이라고 한다. 이에 해당하는 것으로는 민법 490조, 민사집행법 258조 6항, 상법 67조, 70조, 71조, 상법 109조, 113조, 상법 123조, 상법 142조, 143조 1항, 149조 2항, 상법 165조, 상법 753조, 상법 808조 1항 등에 정한 경매가 있다.
- ③ 단주(端株)의 경매 : 통상적인 거래단위 미만의 주식 또는 1주 미만의 주식에 대한

경매를 의미하는데, 상법 443조 1항, 상법 461조 2항, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 265조 3항, 266조 6항, 273조 3항, 274조 6항에 정한 경매가 이에 해당한다.

④ 타인의 권리를 상실시키는 경매 : 어떤 물건에 대한 타인의 권리를 상실시키는 것 자체를 직접적인 목적으로 하여 그 권리에 대한 경매를 인정하는 경우로는 상법 760조, 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 45조 1항에 정한 경매가 있다.

⑤ 청산을 위한 경매 : 어떤 범위의 재산을 한도로 채권자들에게 그 채권액의 비율에 따라 일괄하여 변제하기 위하여 청산을 목적으로 해당 재산을 현금화하는 것으로서, 민법 1037조, 민법 1051조 3항, 민법 1056조 2항에 정한 경매가 있다.

제4절 보전처분의 집행

민사집행법은 제4편에서 보전처분을 규정하고 있지만, 보전처분의 집행이 협의의 민사집행에 해당하지 않는다고 함은 위에서 설명한 바와 같다. 보전처분절차는 보전명령을 받기까지의 보전소송절차와 보전명령을 집행권원으로 한 보전집행절차로 구분되는데, 민사집행법은 가압류의 집행에 대하여 특별한 규정이 없는 한 강제집행에 관한 규정을 준용하고 있고(민집 291조), 가처분절차에는 가압류절차에 관한 규정을 준용함으로써(민집 301조) 가처분의 집행에도 강제집행에 관한 규정을 준용하고 있다.

제3장 민사집행의 집행기관

제1절 의의 및 종류

집행기관은 민사집행의 실시를 직무로 하는 국가의 기관을 말한다.

등기관이나 가족관계등록사무를 처리하는 공무원이 판결에 기하여 등기사항을 기록하거나 가족관계등록부를 정정하는 것은 이른바 광의의 집행으로는 볼 수 있지만, 판결내용의 실현을 위하여 국민에게 직접강제를 가하는 행위가 아니므로 이러한 공무원은 집행기관이 아니다.

민사집행절차는 간이·신속함을 요하므로, 오랜 시일에 걸쳐서 권리관계를 종국적으로 확정하는 수소법원으로 하여금 그 절차를 취급하게 하는 것은 부적당하다. 그러므로 민사집행법은 원칙적인 집행기관으로 집행관과 집행법원을 두고 예외적으로 수소법원을 집행기관으로 하는 경우를 정하고 있다.

제2절 집행기관의 관할

1. 직무관할

어떠한 종류의 집행행위를 어떠한 집행기관으로 하여금 관장하도록 할 것인가를 정하는 것이 직무관할의 문제이다.

- 21 예를 들어, 실력행사를 수반하는 사실적 행동이 필요하고 비교적 간이한 유체동산에 대한 집행을 집행관으로 하여금 취급하게 하고, 관념적 재판으로 충분한 채권에 대한 집행이나 신중한 절차가 필요한 부동산에 대한 집행을 집행법원의 관할로 하며, 집행할 청구권과

집행방법과의 사이에 상당한 재량판단이 필요한 작위·부작위 청구권에 대한 집행을 수소 법원의 권한으로 하는 것과 같다. 이러한 직무관할은 절대적 강행성을 가지고 이에 위반한 집행행위는 무효이다.

2. 토지관할

같은 종류의 집행기관 중 어떤 곳의 기관으로 하여금 특정한 집행행위를 취급하도록 하느냐를 정하는 표준을 말한다. 집행기관의 토지관할을 인정하는 이유는 개개의 집행행위를 신속·확실하게 할 수 있는 관할구역 내에 있는 기관에 맡기는 것이 타당하기 때문이다. 그러므로 토지관할 위반이 있더라도 추상적으로 직무관할을 가지는 이상 그 집행행위는 이해관계인의 불복신청에 의하여 취소될 수 있을 뿐 당연히 무효가 되는 것은 아니다.

제1편
제3장
제3절

3. 관할을 정하는 표준

집행기관의 관할은 소(訴)의 관할과 달리 하나의 집행절차 전체에 관하여 정하여지는 것이 아니라 개개의 집행행위에 관하여 정하여진다.

따라서 하나의 집행절차에 여러 종류의 집행기관이나 여러 곳의 집행기관이 관여하는 경우도 있다.

예를 들어, 어음, 수표 등과 같이 배서로 이전할 수 있는 증권으로서 배서가 금지된 증권 채권의 압류명령은 집행법원이 발하나 그 증권의 점유집행은 집행관이 행하고(민집 233조), 그 현금화방법인 전부명령·추심명령은 집행법원이 발한다(민집 229조). 유체동산의 압류와 경매가 다른 지방법원 관할구역 내에서 실시되는 경우(민집 203조 1항 단서)에는 따로 토지 관할을 가지는 집행관이 집행한다.

제3절 집행관

22

1. 의의

집행관은 법률이 정하는 바에 따라 재판의 집행, 서류의 송달, 그 밖에 법령에 따른 사무에 종사하는 독립된 단독제의 사법기관이다(법조 55조, 집행관법 2조). 집행관은 자기의

판단과 책임하에 독립적으로 국가의 권한을 행사하는 기관이고 법원 또는 법관의 단순한 보조기관이 아니다.

기관인 집행관을 구성하는 자연인인 집행관은 실질적 의미에 있어서 국가공무원이다. 따라서 집행관은 영리업무의 겸직금지와 그 밖의 겸직제한에 관한 국가공무원법 64조, 법원공무원규칙 88조의 적용을 받으며(행정예규 270호), 집행관이 그 직무를 수행함에 있어 주의의무를 위배함으로써 손해를 가한 경우 국가는 그 피해자에게 국가배상법 2조에 의하여 손해를 배상할 의무가 있다(대판 1966. 7. 26. 66다854, 대판 1968. 5. 7. 68다326). 판례는 집행관으로서 당연히 알아야 할 관계 법규를 알지 못하고 필요한 지식을 갖추지 못하거나 조사를 게을리하여 법규의 해석을 그르치는 등으로 인하여 타인에게 손해를 가하였다면 불법행위가 성립한다고 한다(대판 2003. 9. 26. 2001다52773).

2. 집행관의 임명과 감독 및 집행관사무소의 설치

집행관은 10년 이상 법원주사보·등기주사보·검찰주사보 또는 마약수사주사보 이상의 직급으로 근무하였던 사람 중에서 지방법원장이 임명하며 그 지방법원에 소속된다(법조 55조 1항, 집행관법 2조, 3조, 행정예규 1173호). 집행관의 정년은 61세이고, 임기는 4년으로 하며 연임할 수 없다(집행관법 4조 2항, 3항). 집행관은 소속 지방법원장에 의하여 사법행정상의 감독을 받으며(집행관법 7조 1항), 지방법원 지원의 관할구역 안에 있는 집행관에 대하여는 지원장이 지방법원장의 명을 받아 감독한다(집행관법 7조 2항). 그러나

23 기관으로서의 집행관은 전술한 바와 같이 자기의 판단과 책임하에 권한을 행사한다.

집행관은 소속 지방법원 관할구역에서 지방법원장 또는 지원장이 지정한 곳에 사무소를 설치하여야 한다(집행관법 8조 1항).

3. 출장소의 설치와 집행관 직무의 대행

지방법원의 지원 소재지에 집행관이 없는 경우에는 지방법원장은 그 관할구역의 집행관에게 지원 소재지에 출장소를 설치하도록 명하거나 지방법원 및 지원의 법원서기관·법원사무관·등기사무관·법원주사·등기주사·법원주사보 또는 등기주사보(이하 '법원서기관 등')로 하여금 집행관의 직무를 대행하게 할 수 있다(집행관법 11조 1항). 지방법원장은 지방법원 및 지원의 법원서기관 등으로 하여금 집행관의 직무를 대행하게 하는 경우에는 대행할 사람을 미리 지정하여야 한다(집행관법 11조 2항). 집행관이 질병, 제척 등 정당한 이유로

그 직무를 수행할 수 없을 때에 지방법원장 또는 지원장은 그 직무의 집행을 다른 집행관이나 대행자로 지정되어 있는 법원서기관 등에게 명하여야 한다(집행관법 16조 3항).

집행관의 직무를 행하는 법원서기관 등은 집행관의 직무에 관한 한 독립된 기관으로서의 지위를 누리며 상사의 지휘에 따라야 하는 것은 아니다. 법원서기관 등이 집행관의 직무를 대행하는 경우에도 당사자는 집행관이 직무를 행하는 경우와 동일한 수수료(집행관 수수료규칙 2조 ~ 19조)와 비용(집행관수수료규칙 20조)을 지급하여야 한다. 그러나 이들은 국가로부터 봉급을 받는 법원직원이므로 수수료는 모두 국고수입으로 한다(집행관법 19조 3항). 그리고 집행관수수료규칙 20조의 비용 중 서기료는 국고수입으로 하나, 그 밖의 비용은 실비로서 세입세출의 현금출납의 대상으로 되어 집행관직무대행자는 이를 예납금으로부터 수시로 지출하여 직무집행에 충당할 수 있다. 집행관직무대행자가 직무집행상 여행을 하는 경우에는 '법원공무원 여비 규칙'에 의하여 여비, 숙박료 등을 지급받되, 24 그 액이 집행관수수료규칙 22조의 기준에 미달할 때에는 이 기준에 의하여야 할 것이다.

집행관수수료규칙 25조의 예납 없이 직무를 집행하는 때(소송구조를 받는 경우)에는 모든 비용을 국가의 일반 세출예산에서 대납하여야 하는데, 이 비용에 상당하는 상환금은 국고의 수입으로 된다.

4. 집행관의 제척

집행관은 다음의 경우에는 그 직무집행에서 제척된다(집행관법 13조).

① 자기 또는 배우자나 자기 또는 배우자의 4촌 이내의 혈족 또는 인척이 당사자 또는 피해자이거나 당사자 또는 피해자와 공동권리자·공동의무자 또는 상환의무자의 관계가 있는 경우

② 자기 또는 배우자나 자기 또는 배우자의 4촌 이내의 혈족 또는 인척이 당사자, 피해자 또는 그 배우자의 친족인 경우(인척의 경우에는 혼인이 해소되었을 때에도 또한 같다)

③ 자기가 동일한 사건에 관하여 증인 또는 감정인이 되어 신문을 받았던 경우 또는 법률상 대리인이 될 권리가 있거나 있었던 경우

제척사유가 있는 집행관이 한 압류나 그 밖의 집행행위는 당연히 효는 아니고 이해관계인의 집행에 관한 이의신청에 의하여 취소될 수 있음에 불과하다.

한편 집행관에 있어서 기피나 회피의 제도는 인정되지 않는다.

5. 집행관에 대한 수수료 및 비용

(1) 집행관은 국가로부터 봉급을 받지 않고, 사인의 위임 또는 국가기관(법원, 검사)의 명령에 의하여 취급한 사건에 관하여 법정의 수수료를 받을 뿐이다(집행관법 19조 1항). 다만 법원 또는 검사의 명령에 의하여 서류와 물품의 송달, 영장의 집행 등의 사무를 처리
 25 하는 경우에는 체당금 외에 수수료를 받지 못한다(집행관법 20조). 집행관은 정하여진 수수료를 초과하여 징수하거나 특별한 보수를 받지 못하며, 법원서기관 등이 집행관의 직무를 행한 경우의 수수료는 국고수입으로 한다(집행관법 19조 2항, 3항). 집행관의 수수료는 집행관수수료규칙에 정하여져 있다.

(2) 집행관은 서기로, 통신료, 공고료, 감정인 및 참여인의 일당·여비·감정료, 물건의 운반·보관·감수 및 보존비용, 집행관의 여비 및 숙박료 등 법정의 제반 비용을 지급받는다(집행관수수료규칙 20조). 집행관의 직무집행을 위한 일당 및 여비는 ‘법원공무원 여비 규칙’ 중 5급 공무원과 동액으로 한다(집행관수수료규칙 22조). 법원공무원 5급의 여비는 ‘법원공무원 여비 규칙’ [별표 2]의 2호를 참조하면 된다.

집행관이 동일채권자의 위임에 의하여 같은 날 동일하거나 근접한 곳에서 2건 이상의 압류 등 집행행위를 한 경우의 여비는 1건에 해당하는 분만을 받는다. 채권자를 달리하는 2건 이상의 압류 등 집행행위를 같은 날 같은 특별시·광역시·시·군 내에서 실시한 경우 그 장소가 근접하지 않은 때에는 사건마다 각각 여비를 받을 수 있을 것이나, 그 장소가 동일하거나 근접한 때에는 1건에 해당하는 분만의 여비를 받아야 하고, 이때 각 사건 당사자가 안분하여 그 여비를 부담한다(행정예규 787호 22조).

(3) 집행관은 모든 사무를 담당함에 있어서 수수료 기타 비용의 계산액을 위임자에게 예납시킬 수 있고 예납하지 아니하는 때는 위임에 응하지 아니할 수 있다(집행관수수료규칙 25조 1항). 예납 제도는 집행관의 편의를 위한 것이므로, 집행관이 예납을 받지 않고 사무를 실시하여도 그로 인하여 발생하는 불이익을 집행관이 감수하는 한 무방하다.

예납하여야 할 금액은 사건의 종국에 이르기까지에 필요한 것으로 예정되는 수수료 등의 계산액이다.

집행위임 시에 예납을 받을 것이나, 집행관이 사무를 개시한 후 예납금이 부족한 때에는 추가예납을 시킬 수 있고 추납하지 아니하는 때에는 사무를 행하지 아니할 수 있다(집행관수수료규칙 25조 2항).

26 예납명령은 말 또는 서면으로 할 수 있다. 실무상으로는 말로 예납명령을 하고 납부를

받으면 수수료 및 비용의 내역을 명기한 영수증을 납부인에게 교부한다. 예납명령에 대하여 불복이 있으면 집행에 관한 이의신청으로 다룰 수 있다. 집행관이 당사자로부터 직접 집행 위임을 받는 경우에는 집행관 스스로 예납을 받아 이를 보관·지출하지만, 법원의 명령에 의하여 사무를 처리할 경우, 예를 들어 강제경매에 있어서의 현황조사, 경매의 실시나 선박의 감수보존 등의 경우에는 법원이 당사자로부터 예납을 받아 집행관의 사무실시 결과에 따라 집행관에게 지급한다. 사무가 종료한 때에는 집행관은 지체 없이 예납금의 정산을 하여야 하고, 예납자의 청구가 있는 때에는 정산의 내용을 명시한 서면을 교부하여야 한다(집행관수수료규칙 25조의2). 집행관수수료 및 비용에 대한 집행관의 예납금 보관·지출·환급에 관하여는 ‘정보처리시스템에 의한 집행관 사무처리지침(행정예규 1201호)’에 따른다.

집행관은 예납이 없으면 위임에 응하지 않을 수 있으나 예외적으로 강제집행 신청인이 소송구조를 받는 사람인 때에는 예납 없이도 위임에 응하여야 한다(집행관수수료규칙 25조 1항 단서). 이 경우에 위임자는 소송구조를 받는 사실을 증명하는 서면(예를 들어, 소송구조결정의 정보이나 등본 또는 법원사무관등의 증명서)을 제출하여야 한다.

6. 집행관의 관할

가. 토지관할

집행관의 토지관할은 다른 법령에 정하여져 있는 경우를 제외하고는 임명받은 지방법원 본원 또는 지원의 관할구역이다(집행관규칙 4조 1항 본문). 그러나 집행개시 후 법원의 관할구역이 변경된 경우에는 종전법원 소속집행관이 집행을 속행한다(집행관규칙 4조 1항 단서). 이 경우의 감독법원은 그 집행관이 소속한 지방법원이다. 또 집행관은 동시에 집행할 여러 개의 물건이 동일 지방법원 관할구역 내인 본원과 지원 상호 간의 관할에 산재해 있는 경우에는 소속 지방법원장의 허가를 얻어 집행할 수 있다(집행관규칙 4조 2항). 관할을 위반한 집행관의 집행행위는 위법하나 집행에 관한 이의신청(민집 16조 1항)을 할 수 있을 뿐 당연무효로 되는 것은 아니다.

한편 경매신청 전 자동차인도명령에 있어서, 2015년 개정 전의 구 민사집행규칙 113조 1항은 인도명령을 발령한 법원 소속 집행관이 인도명령을 집행할 수 있는 것으로 규정하였으나, 현행 민사집행규칙 113조 1항은 현재 자동차 소재지를 관할하는 법원 소속 집행관이 인도명령을 집행할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 인도명령 발령 후 자동차의 소재지가 변경된 경우에 다시 인도명령을 받아야 하는 불합리를 개선한 것이다.

나. 집행에 관한 직무관할

집행관은 민사집행의 원칙적인 집행기관으로 되어 있으나(민집 2조), 여기에는 널리 예외가 인정되어 실제 그 직무는 주로 사실행위를 수반하는 집행처분에 한한다. 직무관할에 위반한 집행관의 집행행위는 무효이다. 집행관 직무관할의 구체적인 예는 다음과 같다.

(1) 독립의 집행행위

- ① 유체동산에 대한 압류집행(민집 189조)
- ② 유체동산에 대한 가압류집행(민집 296조)
- ③ 동산 인도청구의 집행(민집 257조)
- ④ 부동산·선박 인도청구의 집행(민집 258조)
- ⑤ 담보권 실행 등을 위한 동산의 경매(민집 272조, 274조)
- ⑥ 인도단행가처분 등 일정한 내용의 가처분의 집행(민집 301조, 296조, 305조)

(2) 집행법원이 행하는 집행절차에 부수된 행위

- ① 지시증권상 채권의 압류에서 증권의 점유(민집 233조)
- 28 ② 채권압류에서 채권증서의 취득(민집 234조 2항)
- ③ 유체동산에 관한 청구권에 대한 집행에서 목적물의 수령 및 현금화(민집 243조 1항, 3항)
- ④ 그 밖의 재산권에 대한 집행에서 그 재산권의 매각 등의 방법에 의한 현금화(민집 251조 1항)
- ⑤ 부동산의 강제경매, 강제관리, 담보권 실행 등을 위한 경매에서 목적물의 현황 조사(민집 85조, 163조, 268조, 274조)
- ⑥ 부동산, 선박, 자동차 등의 강제경매·담보권 실행 등을 위한 경매에서 매각의 실시(민집 107조, 112조, 172조, 187조, 268조, 269조, 270조, 274조)
- ⑦ 부동산 강제관리에서 관리인의 부동산 점유시의 원조(민집 166조 2항)
- ⑧ 매각된 부동산의 인도명령의 집행(민집 136조 6항, 268조, 274조)

7. 집행실시에 관한 일반적 절차

가. 집행위임

채권자는 그 관내의 집행관 중 누구에게라도 집행의 위임을 할 수 있다. 이 위임은 민법

상의 위임과는 다르며 집행의 개시를 구하는 신청이라고 볼 것이다.

집행관에게 집행을 위임함에 있어서는 집행력 있는 정보를 교부하여야 한다(민집 42조 1항).

집행의 위임은 강제집행개시의 전제조건이다. 다만 집행위임이 있더라도 집행을 개시하기 위해서는 일정한 요건을 필요로 한다(민집 39조, 40조, 41조).

(1) 위임자의 능력

위임자는 소송능력자임을 요하며 대리인에 의한 위임에는 유효한 대리권의 수여를 필요로 하고 그 권한은 위임장으로 증명하여야 한다.

(2) 집행위임의 방식

채권자의 집행위임은 서면으로 하여야 한다(민집 4조). 신청서의 양식은 ‘집행관사무소에 비치할 각종 문서의 양식에 관한 예규(행정예규 1200호)’ 부록 3-1에 정해져 있고, 집행관사무소에 비치되어 있는데(집행관규칙 12조, 행정예규 1200호 2조), 그 서면에는 채권자의 이름과 주소(대리인이 있는 경우에는 대리인의 이름), 채무자의 이름과 주소, 집행목적물의 소재지, 집행권원, 집행의 목적물 및 집행방법(압류, 인도 등), 청구금액 등을 적어야 한다. 유체동산에 대한 강제집행신청서에 집행의 목적물을 지정하여 적을 필요는 없고 ‘강제집행의 목적물인 유체동산이 있는 장소’를 적으면 된다(민집규 131조 3호).

실무상 집행의 편의를 위하여 집행목적물의 소재지 약도를 첨부하도록 하고 있다.

신청서에는 집행력 있는 정보(민집 42조 1항)와 집행개시의 요건을 충족하였음을 증명하는 서면(민집 39조, 40조, 41조)을 첨부하여야 하고, 신청 시에는 집행관수수료규칙 25조 1항에 따라 비용을 예납하여야 한다.

연대채권 또는 불가분채권의 경우에 각 채권자는 채권 전부에 관하여 집행위임을 할 수 있으나 가분채권인 경우에는 자기의 채권액에 관하여서만 집행위임을 할 수 있다. 연대채무 또는 불가분채무의 경우에 채권자는 각 채무자에 대하여 채권 전부의 집행위임을 할 수 있으나, 가분채권의 경우에는 각 채무자에 대하여 그 부담부분에 한하여 집행위임을 할 수 있다. 조합채권과 같은 합유채권의 경우에는 채권자 전원이 공동으로 집행위임을 하여야 한다.

집행관이 집행사건을 수임할 경우 위임인을 확인하기 위하여 다음과 같은 조치를 취하여야 한다(행정예규 495호, 재민 77-2).

① 위임인으로 하여금 주민등록증을 제시하게 하여 채권자 본인인지 또는 권한 있는 대리인인지 여부를 확인하고 직무부 등 채권자 또는 경매신청인 등의 이름 기재란에 주민

등록번호를 병기하여야 한다.

- 30 ② 변호사가 채권자의 대리인으로서 그 사무원으로 하여금 집행사건을 위임케 하는 경우에 집행관은 그 사무원임을 증명하는 신분증과 주민등록증을 제시하게 하여 이를 확인하고 각종 장부에 기재할 위임인의 이름란에는 변호사의 이름 다음에 사무원의 이름, 주민등록번호와 사무원증번호를 병기하여야 한다.

③ 압류직무부 등의 비고란에 위임인(변호사 사무원이 집행위임한 경우는 그 사무원)의 인장을 압날할 수 있다.

한편 집행관사무가 전산화(2003년)된 이후로는 각종 직무부가 전산에 의해 관리되므로, 별도의 장부로 작성·비치되지 않는다. 또한 개인정보 보호법이 시행됨에 따라 실무상 대리인의 주민등록번호를 병기하는 업무는 하지 않고 있다. 다만 집행관사무소의 접수담당자는 위 예규가 제정된 취지에 따라 위조된 집행권원이나 위임장이 첨부되어 있지는 않은지에 대하여 면밀히 살펴야 할 것이다.

(3) 집행위임의 거절

집행관은 집행위임이 있으면 위임의 요건을 조사하여 형식적 요건이 구비되어 있는 한 정당한 사유(관할권의 부존재, 제척원인의 존재, 비용의 미납 등) 없이 위임을 거절할 수는 없으나(집행관법 14조), 흠결이 있는 때에는 그 보완을 요구하고 보완이 없으면 위임을 거절할 수 있다. 거절에 불복이 있는 사람은 집행관 소속의 집행법원에 이의를 신청할 수 있다(민집 16조 3항).

(4) 집행위임의 취하

집행의 실시는 채권자의 의사에 의존하는 것이므로 채권자는 집행종료 전이면 언제든지 집행위임을 취하할 수 있다. 그러나 집행관은 정당한 사유 없이는 수임 후에 직무수행을 그만둘 수 없다.

(5) 집행위임의 효과

위임을 받은 집행관은 집행기관으로서 독립하여 자기의 책임과 판단으로 법규에 따라 그 권한을 행사하여야 하며 채권자의 지시를 따를 필요는 없다.

- 31 채권자로부터 적법한 위임을 받은 때에는 집행관은 특별한 권한을 받지 못하였더라도 지급이나 그 밖의 이행을 받을 권한이 있다(민집 42조 1항). 채권자는 집행관의 위 권한을 제한할 수 있다. 그러나 집행관이 그 제한에 저촉되는 행위를 하더라도 집행력 있는 정본

을 소지한 집행관에 의하여 행하여진 이상 채권자는 채무자나 제3자에 대하여 그 제한을 주장할 수 없다(민집 43조 1항).

위임을 받은 집행관은 사건의 처리를 다른 집행관에게 위임하지 못한다. 다만 명령 또는 위임을 한 사람의 승낙이 있는 경우에는 그렇지 않다(집행관규칙 16조).

(6) 특별위임

집행관이 채권자로부터 특별한 위임을 받은 때에는 민사집행법 42조에 규정되어 있지 아니한 행위, 특히 화해, 변제의 연기, 대물변제의 수령 등 일정한 사법상의 권한을 행사할 수 있다. 이것은 집행의 원활화와 신속, 정확한 실시를 가능케 하는 것이므로 허용하여도 무방하기 때문이다. 이러한 범위에 있어서 집행관은 개인으로서 채권자의 임의대리인이 될 것이다.

제1편
제3장
제3절

나. 집행일시의 지정, 통지

집행관이 민사집행의 신청을 받은 때에는 바로 민사집행을 개시할 일시를 정하여 신청인에게 통지하여야 한다. 다만 신청인이 통지가 필요 없다는 취지의 신고를 한 때에는 그렇지 않다(민집규 3조 1항). 위 집행일시는 부득이한 사정이 없으면 신청을 받은 날부터 1주일 안의 날로 정하여야 한다(민집규 3조 2항).

다. 집행현장에서의 절차

명문의 규정은 없지만, 집행관은 집행현장에 임하여 집행 전에 임의이행을 촉구할 것이며 집행개시를 하였다 하여 임의이행을 거절할 수 없다. 집행관은 인도집행 등의 제1회 기일에는 집행현장에서 채무자에게 임의이행을 촉구하며 제2회 기일을 지정하고, 그 기일까지 임의이행이 없는 경우에 비로소 인도집행 등으로 나아가는 것이 통상적인 실무이다.

집행관은 그 직무를 집행할 때에는 지방법원장이 교부한 신분증 및 집행력 있는 정본을 가지고 있어야 하고(민집 43조 2항, 집행관법 17조 1항), 관계인이 요청할 때에는 그 자격을 증명하기 위하여 이를 내보여야 한다(민집 43조 2항, 집행관규칙 15조).

집행관 외의 사람으로서 법원의 명령에 의하여 민사집행에 관한 직무를 행하는 사람(예를 들어, 민집 97조의 감정인 등)도 그 신분 또는 자격을 증명하는 문서를 지니고 있다가 관계인이 신청할 때에는 이를 내보여야 한다(민집 7조 1항).

라. 야간·휴일의 집행

공휴일과 야간에는 집행법원의 허가가 있어야 집행행위를 할 수 있다(민집 8조 1항). 주간 또는 평일에 착수한 집행행위의 속행으로 야간이나 휴일에 이른 때에도 이 허가가 있어야 한다. 야간이란 일몰 후부터 일출 전까지이다. 여기서 말하는 집행행위는 압류, 수색과 같은 실행행위를 말하고, 집행력 있는正本이나 집행문의 송달, 그 밖의 집행에 관한 명령의 송달이나 진술을 구하는 최고 등(민집 39조, 227조 2항, 229조 4항, 237조 2항, 240조 2항, 251조 2항 등)은 이에 포함되지 않는다.

(1) 허가신청

신청은 채권자는 물론 집행관도 할 수 있다. 채권자가 신청을 하는 경우에는 1,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 신청은 집행사건으로 접수(사건부호는 타기)하여 집행사건부에 전산입력한 후 별책으로 만든다(재민 91-1).

(2) 재판

집행법원은 변론 없이 재판할 수 있으며(민집 3조 2항), 필요한 때에는 이해관계인, 그 밖의 참고인을 심문할 수 있다(민집규 2조). 법원은 자유로운 판단에 의하여 결정으로 허부의 재판을 한다.

- 33 허가결정은 “위 당사자 간의 ○○지방법원 20○○가합○○ 손해배상 사건의 집행력 있는 판결정보에 기한 집행은 야간(또는 휴일)에 이를 할 것을 허가한다.”라는 형식이 된다.

허부의 결정은 신청인에게 송달하면 족하고 채무자에게 송달할 필요는 없으나, 허가가 있는 때에는 허가결정을 집행 시에 채무자에게 제시하여야 하므로(민집 8조 2항) 허가결정의 정보를 집행관에게 교부한다.

허부의 재판에 대하여는 집행에 관한 이의신청(민집 16조 1항)을 할 수 있다.

(3) 허가 없이 공휴일 또는 야간에 한 집행행위

집행관이 집행법원의 허가 없이 공휴일 또는 야간에 집행행위를 한 경우에는 채무자는 집행에 관한 이의신청(민집 16조 1항)을 할 수 있다.

마. 채무자·집행 목적물의 조사

집행관은 집행을 함에 있어서 집행을 받는 채무자가 집행권원에 표시된 사람에 해당하는가, 그의 소유재산인가, 그가 점유하고 있는 것인가 등을 조사하여야 한다. 다만 그 개연

성을 인정할 수 있는 외관과 징표에 의하여서만 판단할 수 있을 뿐이며 실질적 조사권은 없다.

바. 수색

집행관은 집행을 하기 위하여 필요한 경우에는 채무자의 주거·창고 그 밖의 장소를 수색하고, 잠근 문과 기구를 여는 등 적절한 조치를 할 수 있다(민집 5조 1항). 집행관은 채무자의 주거에 들어가기 위하여 그것이 채무자의 주거인가를 제반 사정에 의하여 판단할 권한이 있고, 또 직무상의 재량에 의하여 일단 채무자의 주거라고 판단한 경우에는 채무자 이외의 사람이 채무자의 주거가 아니라고 주장한 때에도 그 주장을 확인하기 위하여 그 주거에 들어가 채무자의 소유물건이 있는가 여부를 조사할 수 있다. 만약 창고, 금고 또는 상자 등의 문이 잠겨 있는 때에는 우선 채무자에게 이를 열도록 할 것이고 이에 불응한 때에는 집행관 스스로 또는 제3자에게 명하여 실력으로 열어서 수색할 수 있다. 이때 34
자물쇠를 파손하지 않고서는 이를 열 수 없는 경우에는 필요한 한도에서 파손이 있더라도 불가피하다. 그러나 이러한 경우라도 채무자에게 가장 손해가 적은 방법을 선택하여야 할 것이다. 채무자나 그 가족 등이 신체나 의복 등에 채무자 소유의 현금이나 귀금속 등을 감추고 있는 것이 분명하다고 인정될 때에는 호주머니, 옷소매 등을 검사하여도 무방할 것이다.

사. 저항의 배제

집행을 함에 있어 집행을 방해하는 저항을 받으면 집행관은 경찰 또는 국군의 원조를 요청할 수 있다(민집 5조 2항).

여기서 저항은 구체적인 집행행위에 대한 것에 한하며, 일단 집행행위를 완전히 종료하여 그 효력이나 상태가 계속 중에 채무자 또는 제3자가 그 집行的 효과를 배제하려고 실력을 행사하는 등의 경우는 포함되지 않는다. 그러나 반드시 집행 중인 경우에만 한하는 것이 아니라 집행개시 직전 또는 종료 직후 이에 근접한 시점도 포함되는 것으로 보는 것이 타당하다. 따라서 가령 건물인도의 강제집행에 있어서 집행관이 이를 실시하기 위하여 목적 건물에 들어가거나 또는 들어가려고 한 때에는 비록 현실로 인도집행의 내용을 이루는 사실행위, 예를 들어 동산의 반출, 채무자의 배제 등에 착수하지 않았다 하더라도 이에 포함되며, 또 집행관이 채무자의 목적 건물에 대한 점유를 풀고 채권자에게 그 점유를 넘겨준 직후에 채무자가 다시 목적 건물에 들어가 그 점유를 침탈하려고 실력을 행사하는

경우에도 그 저항을 배제할 수 있다. 저항은 적극적 저항뿐만 아니라 소극적 저항 또는 협박과 같은 언어에 의한 저항도 포함한다. 그러나 가령 채무자 또는 그의 가족이 와병 중에 있어 퇴거로 인하여 병상이 현저히 악화될 우려가 있는 등의 사정이 있는 경우에는 소극적 저항이라고 볼 수 없을 것이다. 따라서 이와 같은 경우에는 그 병상을 확인할 필요가 있으며 경우에 따라서는 의사의 진단서 등의 제출을 요구할 수도 있다. 이때 채무자 등이 진단서의 제출을 거부할 때에는 질병을 가장한 저항으로 보아 이후의 절차를 취하더라도 무방하다 할 것이다.

채무자의 저항은 물론 제3자의 저항도 포함되며 저항이 집행관 자신에 대하여 가하여진 것인가 집행보조자에게 가하여진 것인가를 묻지 않는다.

그러나 집행관 스스로 어느 정도의 위력을 사용하여 그 저항을 간단히 배제할 수 있는 경우라면 경찰 또는 국군의 원조를 요청할 필요는 없을 것이다. 집행행위의 종료 후에 압류 등의 효과를 배제시키려고 하는 경우, 예를 들어 압류물의 양도, 반출 등은 여기서 말하는 저항이 아니다.

집행관이 경찰에 대한 원조요청을 할 필요가 있다고 판단되는 때에는 사전에 그 집행에 관한 직무의 수행장소를 관할하는 경찰서장에게 경찰원조요청서[전산양식 A3101]에 의하여 집행 시 경찰의 원조가 필요한 사유를 통지하면서 원조를 요청할 수 있고, 다만 관할 경찰서장에게 사유를 통지하면서 경찰의 원조를 요청할 수 있는 시간적 여유가 없을 정도로 긴급을 요하는 때에는 집행장소에서 가장 가까운 곳에 있는 파출소 등의 경찰관에게 구두로 직접 원조를 요청할 수 있으며, 집행관이 해상에서 집행에 관한 직무를 수행함에 있어 경찰에 대한 원조요청을 할 필요가 있다고 판단되는 때에는 가장 가까운 곳에 있는 해양경찰서장에게 위와 같은 통지 및 원조요청을 할 수 있다. 집행관은 채무자 또는 제3자의 저항을 배제하기 위하여 경찰의 원조를 요청하여 집행 시에 그 원조를 받은 때에는 당해 집행에 관한 직무의 수행에 관하여 작성한 집행조서에 저항배제를 위한 경찰원조사실을 기재하여야 하고, 다만 부동산 현황조사 등과 같이 집행조서를 작성하지 아니하는 경우에는 위 사실을 명백히 기재하고 기명날인을 한 서면을 작성하여 집행기록에 가철하여야 한다(재민 99-1).

국군의 원조가 필요하다고 인정한 때에 집행관이 직접 요청할 수는 없고 집행법원에 신청하여 집행법원의 판단에 따라 국군의 원조를 요청하게 된다(민집 5조 3항). 집행법원이 국군의 원조를 요청하는 경우에는 서면으로 하여야 하고, 그 국군원조요청서에는 ① 사건의 표시, ② 채권자·채무자와 그 대리인의 표시, ③ 원조를 요청한 집행관의 표시, ④ 집행할

일시와 장소, ⑤ 원조가 필요한 사유와 원조의 내용을 적어야 하며(민집규 4조 1항), 국군원 36
 조요청서는 법원장 또는 지원장과 법원행정처장을 거쳐 국방부장관에게 보내야 한다(민집
 규 4조 2항).

저항을 배제하는 행위는 바리케이드의 철거 등 대물적인 행위뿐만 아니라 저항하는 사
 람을 직접 밀어내는 등의 대인적인 행위도 허용된다.

집행관 외의 사람으로서 법원의 명령에 의하여 민사집행에 관한 직무를 행하는 사람은
 그 직무를 집행하는 데 저항을 받으면 집행관에게 원조를 요구할 수 있고(민집 7조 2항),
 그 원조요구를 받은 집행관은 민사집행법 5조(강제력 사용, 경찰 또는 국군의 원조 요청),
 6조(증인 참여)에 규정된 권한을 행사할 수 있다(민집 7조 3항).

집행관 외의 사람으로서 법원의 명령에 의하여 민사집행에 관한 직무를 행하는 사람이
 란 감정인(민집 97조), 강제관리의 관리인(민집 166조), 선박의 갑수·보존인(민집 178조)
 등을 말한다. 다만 강제관리의 관리인에 대하여는 민사집행법 166조 2항에 관리인이 관리
 와 수익을 하기 위하여 부동산을 점유함에 있어서 저항을 받으면 집행관에게 원조를 요구
 할 수 있다는 별도의 규정을 두고 있고, 민사집행법 97조 3항은 부동산평가 감정인이 집행
 관의 원조를 요구하는 때에는 법원의 허가를 얻어야 하는 것으로 제한하고 있다.

위 감정인, 관리인 등에 임명된 사람이 집행관인 때에는 민사집행법 7조 2항의 적용이
 없음은 규정 자체에 비추어 명백하다. 집행관이 집행법원의 명령에 의하여 민사집행에 관
 한 직무를 행하는 경우 이는 집행관법 2조에 의하여 집행관의 직무로 되므로, 그 직무를
 집행하는 데 저항을 받으면 다른 집행관의 원조를 구할 필요가 없이 스스로 강제력을 사용
 하거나 경찰 등의 원조를 요청할 수 있다고 할 것이다.

아. 증인의 참여

집행관은 집행하는 데 저항을 받거나 채무자의 주거에서 집행을 실시하려는데 채무자나 37
 사리를 분별할 능력이 있는 그 친족·고용인을 만나지 못한 때에는 성년 두 사람이나 특별
 시·광역시·특별자치시의 구 또는 동 직원, 특별자치시의 동 직원, 시·읍·면 직원(도농복합형태의 시의
 경우 동지역에서는 시 직원, 읍·면지역에서는 읍·면 직원) 또는 경찰공무원 중 한 사람을
 증인으로 참여하게 하여야 하며(민집 6조, 민집규 5조), 위에서 규정된 공무원들은 집행관
 으로부터 집행실시의 증인으로 참여하도록 요구받은 경우 정당한 이유 없이 그 요구를
 거절하여서는 안 된다(민집규 5조).

여기서 말하는 저항이란 실력으로 집행을 방해하는 것은 물론 집행을 거부하는 것도

포함된다 할 것이나, 단순히 말로 이의를 제기한 데 그친 경우에는 저항이라 볼 수 없을 것이다. 경찰에 대한 원조 요청(민집 5조 2항)에 따라 출동한 경찰관은 집행관을 보조하는 입장에 있어 민사집행법 6조에서 정한 집행참여자의 적격성이 없으므로 그 경찰관 이외의 증인이 필요하다(재민 99-1). 채무자가 법인인 경우의 주소, 즉 사무소나 영업소는 이 규정의 적용을 받지 아니하므로 저항이 없는 한 대표자가 없어도 집행할 수 있다. 고용인이란 반드시 채무자와 동거하고 있는 사람일 필요는 없으나, 주거에서 집행하는 경우이므로 가사에 관한 고용인이어야 하고, 채무자가 별도로 사업장을 가지고 경영하는 사업의 종업원은 이에 해당하지 않는다 할 것이다. 집행에 있어 저항이 예상되는 경우에는 미리 증인을 동행하여도 무방하다.

이러한 증인의 참여가 없는 집행행위는 채무자 또는 이해관계인의 집행에 관한 이의신청에 의하여 취소될 수 있으나 당연무효로 되는 것은 아니다. 또한, 채무자의 집행이의권 포기에 의하여 그 하자가 치유되며, 채무자가 집행관을 만났음에도 불구하고 고의로 집행을 참여를 거부할 때도 집행이의권의 포기로 보아 집행의 착수 또는 속행을 할 수 있다.

자. 영수증·집행력 있는 정보의 교부

38 집행관은 임의변제나 그 밖의 이행을 받은 때에는 영수증서를 작성하고 교부하여야 하며 채무자가 그 의무를 완전히 이행한 때에는 집행력 있는 정보를 채무자에게 교부하여야 한다(민집 42조 1항). 만약 여러 통의 집행정보인 교부된 때에는 그 모두를 교부하여야 한다.

(1) 의무를 일부 이행한 경우

이 경우에 집행관이 집행력 있는 정보에 그 사유를 덧붙여 적고 영수증서를 작성하여 채무자에게 교부하여야 한다(민집 42조 2항). 이중의 이행청구나 이중의 집행을 받을 위험을 제거하기 위함이다.

(2) 제3자가 변제한 경우

민법 469조의 제한에 해당하지 않는 한 제3자도 변제를 할 수 있으므로, 이 경우 집행관이 제3자의 변제를 받은 때에는 그 제3자에게 영수증서를 교부하여야 하고, 일부 이행의 경우 집행력 있는 정보에 그 사유를 덧붙여 적어야 함은 채무자가 변제한 경우와 같다. 그러나 그 의무를 완전히 이행한 경우에 집행정보를 누구에게 교부할 것인가에 관하여는 채무자에게 교부할 것이라는 견해와 변제자에게 교부할 것이라는 견해가 있다.

(3) 공동채무자가 변제한 경우

(가) 불가분채무자 또는 연대채무자 중의 1인이 채무 전부를 변제한 때에는 그에게 집행력 있는正本과 영수증서를 교부한다. 그 중 1인이 일부만을 변제한 때에는 그 취지를 집행력 있는 정본에 덧붙여 적고 영수증서를 작성하여 교부한다. 각 채무자가 각각 일부씩을 순차로 변제한 결과 완제가 된 때에는 최후의 변제자에게 집행력 있는 정본을 교부할 것이다.

(나) 분할채무자 중의 1인이 자기 부담부분 전부를 변제하였더라도 그 집행정본은 다른 채무자에 대한 집행에 필요하기 때문에 이를 반환할 수 없고 그 변제의 취지를 집행정본에 덧붙여 적고 영수증서를 작성하여 교부한다. 그리고 전원의 채무가 변제되었다 하더라도 전원을 위한 대리인이 선임되어 있지 않은 한 집행력 있는 정본을 채무자 중 1인에게 교부할 것이 아니라 채무가 전부 이행되었다는 뜻을 집행력 있는 정본에 덧붙여 적은 다음 집행관의 기록에 첨부하여 두는 것이 무난한 처리 방법이 될 것이다.

39

(4) 채무자가 직접 채권자에게 변제한 경우

집행관은 영수증서를 작성하여 교부하거나 집행력 있는 정본을 교부하거나 집행력 있는 정본에 그 사유를 덧붙여 적을 의무는 없으나 채권자가 동의하면 집행력 있는 정본을 채무자에게 교부하여도 무방하다.

(5) 어음·수표의 경우

어음·수표는 상환증권이므로 그 채권의 집행에 있어서 집행관은 그 어음·수표를 채무자에게 제시하여야 한다. 변제가 있는 때에 집행관은 어음·수표에 영수를 증명하는 기재를 하여 집행력 있는 정본과 함께 채무자에게 교부하여야 한다. 다만 어음·수표의 제시와 상환에 의한 변제는 채무자의 이익을 위한 것이므로 채무자가 그 이익을 포기하고 임의변제를 하는 경우에 집행관은 그 제시 없이도 변제를 받을 수 있다.

(6) 채무자의 영수증청구권

채무자가 집행관으로부터 영수증서의 교부를 받을 수 있다고 하여 채권자에 대하여 영수증청구권(민 474조)을 행사할 수 없는 것은 아니다(민집 42조 3항 참조).

또 채무를 완전히 이행한 때에 채무자는 집행관으로부터 집행력 있는 정본을 교부받는 것과 관계없이 채권자에 대하여 채권증서의 반환을 청구할 수 있다 할 것이다(민 475조).

차. 집행조서의 작성

(1) 집행조서 작성 의무

집행관은 집행행위마다 집행조서를 작성하여야 한다(민집 10조 1항). 압류를 한 때에는 압류조서를, 매각기일을 진행한 때에는 매각기일조서를 작성하여야 하며(민집 116조), 가
 40 압류·가처분의 집행에 관하여서도 조서를 작성하여야 한다. 대체집행의 결정에 기초한 집행(민집 260조 1항), 저항배제를 위한 참여(민집 166조 2항), 매각부동산에 대한 인도명령의 집행(민집 136조 6항), 그 밖에 집행관이 직무집행을 함에 있어 강제력을 행사할 수 있는 사무는 모두 집행행위에 해당하므로 조서를 작성하여야 한다. 그러나 정형적인 사무가 아닌 행위, 예를 들어 부동산현황조사, 부동산 강제관리인의 사무 등에 관하여는 조서의 작성이 필요하지 않다. 집행조서의 작성이 집행행위의 유효요건은 아니며, 그 기재에 흠결이 있다 하더라도 집행행위의 효력에 아무런 영향을 주지 않는다. 한편 집행조서의 증명력에 관하여, 집행조서는 변론조서와는 달라서 집행방식에 관한 규정의 준수에 관하여 유일한 증거방법이 아니므로 증인이나 그 밖의 증거에 의한 반대증명이 가능하다는 견해와 집행조서의 경우에도 조서 이외의 증거에 의한 증명이 허용되지 않는다는 견해로 나뉘어 있는데, 판례는 부동산경매절차에서 매각기일의 절차가 적법하게 행하여졌느냐의 여부는 민사소송법 158조를 준용하여 매각기일조서의 기재만이 유일한 증명자료가 된다고 한다(대결 1994. 8. 22. 94마1121). 집행조서는 집행기록의 일부로서 가철되어 3년간 보존되며(집행관규칙 28조 1항 5호 가목), 이해관계인은 집행관에게 신청하여 이를 열람하고 등본·초본을 교부받을 수 있다(민집 9조, 집행관규칙 32조 1항).

(2) 집행조서의 기재사항(민집 10조 2항)

(가) 집행한 날짜와 장소

(나) 집행의 목적물과 그 중요한 사정의 개요 : 집행의 목적물은 집행의 대상이 된 물건을 특정할 수 있도록 적어야 한다. 유체동산 압류조서에 집행의 목적물을 적는 때에는 압류물의 종류·재질, 그 밖에 압류물을 특정하는 데 필요한 사항과 수량 및 평가액(토지에서 분리하기 전의 과실에 대하여는 그 과실의 수확시기·예상수확량과 예상평가액)을 적어야 한다(민집규 134조 2항).

중요한 사정이란 집행관이 현실적으로 행한 집행행위의 구체적 내용 가운데 중요한 사정을 말한다. 집행조서에 기재할 중요한 사정의 개요는 ① 집행에 착수한 일시와 종료한
 41 일시, ② 실시한 집행의 내용(유체동산 호가경매조서에 적을 '실시한 집행의 내용'에 관하

여는 민집규 150조 1항 참조), ③ 집행에 착수한 후 정지한 때에는 그 사유, ④ 집행에 저항을 받은 때에는 그 취지와 이에 대하여 한 조치, ⑤ 집행의 목적을 달성할 수 없었던 때에는 그 사유, ⑥ 집행을 속행한 때에는 그 사유 등이다(민집규 6조 1항).

공휴일·야간집행의 허가재판(민집 8조 1항), 압류금지 물건을 정하는 재판(민집 196조 1항), 특별한 현금화방법의 재판(민집 214조 1항) 등의 집행행위에 관하여 집행법원의 재판이 있는 때에는 그 요지를 기재하는 것이 좋고, 임의변제를 받은 경우 그 내용을 기재하는 것도 이에 속한다.

한편 유체동산 압류조서에는 민사집행법 10조 2항, 3항과 민사집행규칙 6조에 규정된 사항을 적는 외에 채무자가 자기 소유가 아니라는 진술을 한 압류물에 관하여는 그 취지를 적어야 한다(민집규 134조 1항).

(다) 집행참여자의 표시 : 채권자 또는 그 대리인, 채무자 또는 사리를 분별할 능력이 있는 친족이나 고용인, 그리고 이들이 없었던 때에는 참여증인(민집 6조), 매수인 또는 최고가매수신고인 등 집행관계인으로서 집행에 참여한 사람을 표시하여야 한다. 집행관이 보조자로서 사용한 사람과 원조를 한 경찰관 등은 여기의 집행참여자에 해당되지 않는다.

(라) 집행참여자의 서명날인 : 집행참여자의 서명날인은 서명무인으로 갈음할 수 있다(민집규 6조 2항).

(마) 집행참여자에게 조서를 읽어 주거나 보여 주고, 그가 이를 승인하고 서명날인 또는 서명무인한 사실

(바) 집행관의 기명날인 또는 서명

(사) 기타 : 민사집행법 10조의 기재사항은 아니나, 사건을 특정하기 위하여 실무상 당사자의 이름과 사건번호를 기재함이 통례이며, 집행의 기본이 된 집행권원도 기재하는 것이 좋다.

(3) 집행참여자의 서명날인을 받지 못한 경우의 조치

집행참여자로부터 위와 같은 서명날인 또는 서명무인을 받지 못하거나 승인을 받지 못한 때에는 그 이유를 기재하여야 한다(민집 10조 3항). 특히 채무자는 집행조서에 기재한 사항의 승인과 서명날인을 정당한 이유 없이 거부하는 예가 많다. 집행참여자가 서명날인을 거부하는 경우는 물론, 집행 도중 또는 서명날인을 받으려고 할 무렵 현장을 떠나버린 경우 등에도 그러한 사유를 기재하여야 한다. 집행현장에서 조서를 작성할 수 없어 열람 등을 못한 때에는 그 취지를 기재하여야 한다.

카. 최고와 통지

(1) 집행관이 최고 또는 통지를 하여야 할 경우

집행관은 집행에 있어서 이해관계인에게 최고나 통지를 하여야 할 경우가 많다. 최고는 이해관계인에 대하여 일정한 행위를 하도록 촉구하는 것으로서, 그 예로는 ① 기일입찰 또는 호가경매의 방법에 의한 매각기일에 법원이 정한 매각방법에 따라 매수가격을 신고하도록 최고하는 것(민집 112조, 115조 4항), ② 매각기일에 차순위 매수신고를 최고하는 것(민집 115조 1항), ③ 미완성의 어음 등을 압류한 경우에 채무자에게 어음 등에 적을 사항을 보충하도록 최고하는 것(민집 212조 2항) 등이 있다. 집행을 할 때 채무자에 대하여 임의이행을 최고하고 잠근 문과 기구를 열도록 최고하는 것도 이에 속하는 것으로 해석된다. 그러나 민사집행법 216조 1항(압류채권자의 집행관에 대한 최고), 250조(배당요구채권자의 압류채권자에 대한 최고) 등의 최고는 집행관이 하는 것이 아니므로 이에 해당하지 않는다.

통지는 일정한 사항을 이해관계인에게 알리는 것으로서, 그 예로는 ① 동산압류 시 채무자에 대한 압류의 통지(민집 189조 3항), ② 배당요구의 채권자 등에 대한 통지(민집 219조), ③ 채권매각결정의 경우 제3채무자에 대한 통지(민집 241조 5항) 등이 있다.

(2) 최고·통지의 방법과 조서의 작성

- 43 위와 같은 최고나 통지는 집행관이 말로 하고 이를 조서에 적는 것이 원칙이다(민집 11조 1항). 다만 특별한 정함이 있는 경우에는 이에 따라야 하고, 위 규정이 적용되지 않음은 당연하다. 예를 들어, 압류채권을 매각한 경우 집행관은 채무자를 대신하여 제3채무자에게 서면으로 양도의 통지를 하여야 하고(민집 241조 5항), 말로 할 수는 없다.

말로 최고나 통지를 할 수 없는 경우에는 민사소송법 181조, 182조 및 187조의 규정을 준용하여 그 조서의 등본을 송달하면 된다(민집 11조 2항). 즉, 군사용의 청사 또는 선박에 속하여 있는 사람에 대한 송달(민소 181조), 교도소·구치소 또는 국가경찰관서의 유치장에 체포·구속 또는 유치된 사람에 대한 송달(민소 182조)과 같은 경우에는 집행관이 말로 최고나 통지를 할 수 없으므로 조서의 등본을 그 청사 또는 선박의 장이나 교도소 등의 장에게 송달하면 된다. 송달방법은 교부송달, 보충송달, 유치송달의 방법이 원칙일 것이지만, 이러한 방법으로 송달할 수 없는 때에는 등기우편으로 발송할 수 있다(민소 187조, 민소규 51조). 위의 어느 경우에도 송달증서를 작성하지 아니한 때에는 조서에 그 사유를 기재하여야 한다.

또한, 집행하는 곳과 법원의 관할구역 안에서 위 송달을 할 수 없는 경우(집행관 소속의

지방법원 본원 또는 지원의 관할구역 안에서 송달할 수 없는 경우)에는 최고나 통지를 받을 사람에게 등기우편으로 조서의 등본을 발송하고 그 사유를 조서에 적어야 한다(민집 11조 3항, 민집규 9조).

그러나 채무자가 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 집행행위에 속한 송달이나 통지를 하지 아니하여도 된다(민집 12조). 집행행위에 속한 송달이나 통지는 집행행위의 효력에 거의 영향을 미치지 않으므로, 그것을 하지 않음으로써 받게 되는 채무자의 불이익을 무시하고 집행의 신속을 기하여 채권자의 이익을 도모하는 것이 바람직하다고 본 것이다. 다만 강제집행개시의 요건에 해당하는 집행권원·집행문의 송달(민집 39조)이나 집행행위에 해당하는 재판(예를 들어, 강제경매개시결정, 채권압류 및 전부명령)을 고지하는 방법으로 하는 송달은 여기서 말하는 집행행위에 속한 송달에 포함되지 아니하므로 일반의 규정에 따라서 반드시 송달하여야 한다. 이 경우 외국송달에 관한 특례를 정한 민사집행법 13조의 규정이 적용된다. 만일 경매개시결정이 채무자에게 송달되지 않으면 유효하게 경매 절차를 속행할 수 없다(대결 1997. 6. 10. 97마814).

최고나 통지를 받을 사람이 무능력자 등인 경우에는 법정대리인에게 최고나 통지를 하여야 한다(민소 179조 준용).

한편 집행행위에 속하지 않는 최고와 통지는 특별한 규정이 없으면 상당하다고 인정되는 방법으로 할 수 있고(민집규 8조 1항), 이 경우 집행관은 그 취지와 최고 또는 통지의 방법을 기록에 표시하여야 한다(민집규 8조 2항).

또 최고를 받을 사람이 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 최고할 사항을 공고하면 되고, 이 경우 최고는 공고를 한 날부터 1주일의 지나면 효력이 생긴다(민집규 8조 3항).

그리고 민사집행법에 규정된 통지를 제외한 민사집행규칙에 규정된 통지의 경우(민집규 3조 1항, 17조, 23조 2항, 127조 2항, 137조 2항, 142조 1항, 2항, 146조 2항, 155조 2항, 165조 3항, 187조, 193조) 통지를 받을 사람이 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 통지를 하지 않아도 되고, 이 경우 집행관은 그 사유를 기록에 표시하여야 한다(민집규 8조 4항).

타. 집행기록의 열람, 등본의 부여

집행관은 집행조서, 집행위임장, 집행권원 송달증명서 또는 민사집행법 42조에 의하여 교부하지 아니한 서류 등 집행에 관한 서류를 함께 편철하여 집행기록으로 보존하며, 이해

관계 있는 사람이 신청하면 이 집행기록을 볼 수 있도록 허가하고 기록에 있는 서류의 등본을 교부하여야 한다(민집 9조). 집행관규칙 32조는, 당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 집행기록 기타 집행관이 직무상 작성하는 서류의 열람이나 등본·초본의 교부 또는 집행관이 취급한 사무에 관한 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 이 등·초본 또는 증명서에는 그 취지와 작성연월일을 기재하고 집행관이 기명날인하여야 한다고 규정하고 있다.

- 45 집행관은 서류의 보관 또는 직무상의 필요에 따라 기록을 볼 수 있는 일시와 장소 등을 제한할 수 있다. 열람교부 청구인은 집행관수수료규칙 20조, 23조에 의한 서기료나 수수료를 지급하여야 한다.

이해관계인이라 함은 채권자, 채무자나 그들의 승계인, 민사집행법 48조(제3자이의의 소)의 제3자, 배당요구채권자, 매수인 등을 말한다.

만약 집행관이 그 열람을 허가하지 않거나 등본(집행관규칙 32조에서 정한 초본 또는 증명서 포함)의 교부를 거부한 때에는 민사집행법 16조 1항에 의하여 집행에 관한 이의신청을 할 수 있다.

8. 집행실시에 대한 불복신청

집행관의 집행처분, 그 밖에 집행관이 지킬 집행절차에 대하여 불복이 있거나(민집 16조 1항), 집행관이 집행을 위임받기를 거부하거나 집행행위를 지체하는 경우 또는 집행관이 계산한 수수료에 대하여 다툼이 있는 경우(민집 16조 3항)에 당사자 또는 이해관계인은 집행법원에 집행에 관한 이의신청을 할 수 있다. 다만 집행관이 독립한 집행기관으로서가 아니라 집행법원 또는 수소법원의 보조기관으로서 행동한 경우(예를 들어, 부동산매각기일의 실시, 경매부동산의 현황 조사 등)에는 그 처분에 대하여 직접 위 이의신청을 할 수 없다는 것이 통설이다.

제4절 집행법원

1. 의의

집행법원은 민사집행법에서 규정한 집행행위에 관한 법원의 처분이나 그 행위에 관한 법원의 협력사항을 관할하는 법원을 말한다(민집 3조 1항). 민사집행의 실시는 원칙적으

로 집행관이 하나(민집 2조), 비교적 복잡한 법률적 판단을 요하는 집행행위라든가 관념적 46
인 명령으로 족한 집행처분에 관하여는 민사집행법상 특별히 규정을 두어 법원으로 하여
금 이를 담당하도록 하고 있고, 또 집행관이 실시하는 집행에 관하여도 신중을 기할 필요
가 있는 경우에는 법원의 협력이나 간섭이 필요하도록 하고 있는데, 이러한 행위를 하는
법원이 곧 집행법원이다.

집행법원은 원칙적으로 집행절차를 실시할 곳이나 실시한 곳을 관할하는 지방법원이며
(민집 3조 1항), 단독판사가 담당한다(법조 7조 4항). 다만 부동산과 채권에 대한 가압류·
가처분 명령의 집행은 특히 신속을 요하기 때문에 그 집행법원은 가압류·가처분 명령을
한 법원으로 한다(민집 293조 2항, 296조 2항, 301조). 그리고 예외적으로 집행하여야
할 청구권의 존부를 확정하는 소송이 계속된 수소법원이 집행기관으로 되는 경우도 있다.
이에 관하여는 후술한다.

집행법원의 토지관할은 전속관할이지만(민집 21조), 사물관할은 전속관할이 아니므로
단독판사의 관할에 속하는 집행법원의 재판사무를 지방법원 합의부에서 심판하였다 하더
라도 위법이라고 할 수는 없다(대판 1963. 3. 21. 63다70).

제1편
제3장
제4절

2. 관할

가. 토지관할

법률에 특별히 집행법원이 지정되어 있지 아니하면 집행절차를 실시할 곳이나 실시한
곳을 관할하는 지방법원이 당해 집행절차에 관한 집행법원이 된다(민집 3조 1항). 하나의
청구권을 실현하기 위한 하나의 집행절차라고 하더라도 그 절차를 구성하는 여러 집행행
위가 다른 관할구역 안에서 시간을 달리하여 행하여진 경우에는 여러 곳의 법원이 각각
집행법원으로서의 권한을 가지게 된다. 이와 같이 하여 여러 곳의 집행법원이 생긴 경우
각각의 집행행위에 관하여 한번 정하여진 관할은 변동될 수 없다. 예를 들어, 유체동산에
대한 강제집행에서 집행관이 압류동산의 보관을 채무자에게 명하였는데 채무자가 다른 법
원의 관할구역으로 이사하고 압류동산을 새로운 주소지로 옮기면 압류에 관하여는 종전
주소지의 지방법원이, 경매에 관하여는 새로운 주소지의 지방법원이 집행에 관한 이의신
청 등에 대하여 각각 집행법원이 된다.

47

민사집행법과 민사집행규칙에 특별히 집행법원이 지정되어 있는 경우는 다음과 같다.

- ① 재산명시신청의 관할법원(민집 61조 1항)

- ② 채무불이행자명부 등재신청의 관할법원(민집 70조 3항)
- ③ 재산조회신청의 관할법원(민집 74조 1항)
- ④ 부동산에 대한 강제집행절차의 집행법원(민집 79조)
- ⑤ 선박에 대한 강제집행절차의 집행법원(민집 173조)
- ⑥ 법률에 따라 부동산으로 보거나 부동산에 관한 규정이 준용되는 것에 대한 강제집행절차의 집행법원(민집규 41조)
- ⑦ 자동차에 대한 강제집행절차의 집행법원(민집 187조, 민집규 109조)
- ⑧ 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행절차의 집행법원(민집 224조)
- ⑨ 등기 또는 등록을 요하는 그 밖의 재산권에 대한 강제집행절차의 집행법원(민집규 175조 2항)
- ⑩ 부동산가압류의 집행법원(민집 293조 2항)
- ⑪ 선박가압류의 집행법원(민집 295조 2항)
- ⑫ 채권가압류의 집행법원(민집 296조 2항)

집행법원의 토지관할은 전속관할이다(민집 21조). 집행법원이 토지관할에 위배하여 한 집행행위는 위법이지만 당연무효는 아니다. 따라서 즉시항고(민집 15조) 또는 집행에 관한 이의신청(민집 16조)에 의하여 취소되기 전까지는 유효하고, 취소됨이 없이 집행절차가 모두 종료하면 더 이상 그 하자를 다룰 수 없다.

나. 직무관할

집행법원의 직무는 크게 집행행위에 관한 처분과 집행행위에 관한 협력으로 구분된다(민집 3조 1항).

48 (1) 집행행위에 관한 처분

집행법원이 직접 집행행위를 실시하는 경우로서 다음과 같은 것들이 있다.

- ① 부동산, 선박, 자동차·건설기계·소형선박 및 항공기에 대한 금전채권의 집행(민집 78조, 172조, 187조)
- ② 채권과 그 밖의 재산권에 대한 금전채권의 집행(민집 223조)
- ③ 동산에 대한 금전채권의 집행에서 배당절차(민집 252조)
- ④ 물건 인도청구의 집행에서 제3자가 목적물을 점유하고 있는 경우(민집 259조)
- ⑤ 채권과 그 밖의 재산권, 부동산, 선박, 자동차·건설기계·소형선박 및 항공기에 대한

가압류·가처분의 집행(민집 291조, 293조, 296조, 301조)

(2) 집행행위에 관한 협력

집행관이 할 집행행위를 보조하고 또는 이를 시정, 간섭하는 경우로서 다음과 같은 것들이 있다.

- ① 국군·공공기관에 대한 원조 요청(민집 5조 3항, 20조)
- ② 공휴일·야간 집행의 허가(민집 8조 1항)
- ③ 집행에 관한 이의신청에 대한 재판(민집 16조)
- ④ 급박한 경우의 집행 정지·속행 등에 관한 잠정처분(민집 46조, 48조)
- ⑤ 집행에 관한 특별대리인의 선임(민집 52조 2항)
- ⑥ 압류금지물건을 정하는 재판(민집 196조)
- ⑦ 유체동산의 특별현금화명령(민집 214조 1항)
- ⑧ 부동산 인도청구의 집행에서 집행의 목적물이 아닌 동산의 매각허가(민집 258조 6항)

제1편
제3장
제4절

다. 시·군법원의 관할에 대한 특례

민사집행법 22조는 시·군법원의 관할과 관련하여 다음 사건은 시·군법원이 있는 곳을 49
관할하는 지방법원 또는 지방법원 지원의 관할로 규정하고 있다.

- ① 시·군법원에서 성립된 화해·조정(민사조정법 34조 4항에 따라 재판상의 화해와 동일한 효력이 있는 결정을 포함한다. 이하 같다) 또는 확정된 지급명령에 관한 집행문 부여의 소, 청구이의의 소 또는 집행문부여에 대한 이의의 소로서 그 집행권원에서 인정된 권리가 소액사건심판법의 적용대상이 아닌 사건
- ② 시·군법원에서 한 보전처분의 집행에 대한 제3자의이의 소
- ③ 시·군법원에서 성립된 화해·조정에 기초한 대체집행 또는 간접강제
- ④ 소액사건심판법의 적용대상이 아닌 사건을 본안으로 하는 보전처분

3. 집행법원의 재판

가. 집행법원의 심리와 재판의 형식

집행법원의 집행에 관한 행위(집행행위에 한하지 않고 집행관에 대한 협력행위도 포함한다)는 모두 결정의 형식에 의한 재판으로 한다. 이 재판은 변론 없이 할 수 있다(민집

3조 2항). 그러나 집행법원은 집행처분을 하는 데 필요한 때에는 이해관계인, 그 밖의 참고인을 심문할 수 있다(민집규 2조).

민사집행법이 규정하고 있는 심문과 관련한 특칙을 정리하면 다음과 같다.

① 필요적 심문 : 집행법원이 추심명령에서 채무자의 신청에 따라 압류액수를 제한할 때에는 반드시 압류채권자를 심문하여야 하고(민집 232조 1항), 집행법원이 채권자의 신청에 따라 압류채권에 대한 특별한 현금화방법을 허가하는 결정을 할 때에는 반드시 채무자를 심문하여야 하며(민집 241조 2항), 법원(수소법원)이 대체집행과 간접강제의 결정을 하기 전에 반드시 채무자를 심문하여야 한다(민집 262조). 또한, 강제관리절차에서 관리인을 해임할 경우에는 관리인을 심문하여야 한다(민집 167조 3항).

② 원칙적 심문 : 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 재판에는 원칙적으로 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 한다. 다만 그 기일을 열어 심리하면 가처분의 목적을 달성할 수 없는 사정이 있는 경우에는 변론기일 또는 심문기일을 열지 않고 재판할 수 있다(민집 304조).

③ 심문의 제한 : 배당표 확정절차에서는 절차의 신속성이 요청되고 배당이의소송이 허용되는 점 등에 비추어, 출석한 이해관계인과 배당을 요구한 채권자에 한하여 심문한다(민집 149조 2항).

④ 심문의 금지 : 채권 등에 대한 압류명령을 하기에 앞서 채무자나 제3채무자를 심문하여서는 안 된다(민집 226조).

민사집행법 3조 2항과 민사집행규칙 2조의 적용범위에 관하여는 견해가 나뉘고 있다. 제1설은, 집행처분은 재판보다 넓은 개념으로서 물건명세서의 작성과 같은 집행처분뿐만 아니라 즉시항고나 집행에 관한 이의신청에 대한 재판도 포함되며, 집행법원은 널리 이러한 집행처분을 함에 있어 민사집행규칙 2조에 의하여 직권으로 이해관계인이나 그 밖의 참고인을 심문할 수 있다고 한다. 이에 대하여 제2설은, 대립당사자가 없는 경우는 별론으로 하되 즉시항고나 집행에 관한 이의신청과 같이 당사자가 대립하고 있는 경우에 당사자 심문 이외에는 구술변론을 열어 당사자의 증거신청을 받아 증인으로 신문하여야 한다고 주장한다. 제1설이 다수설로 보인다. 다만 즉시항고나 집행에 관한 이의신청에 대한 재판에서는 구술변론을 열어 증인신문의 방법에 의하는 것이 타당한 경우도 있을 것이므로 집행법원이 구체적인 사정에 따라 적절하게 선택하면 될 것이다.

나. 재판의 고지

(1) 고지의 방법

집행법원의 결정은 상당하다고 인정되는 방법으로 고지하면 효력이 발생하고, 법원사무관등은 고지의 방법·장소와 날짜를 재판의 원본에 덧붙여 적고 날인하여야 한다(민집 23조 1항, 민소 221조). 전자소송으로 진행되는 사건의 경우에 민사소송법 221조 2항에 따른 절차는 그 취지를 전자소송시스템에 전자적 방법으로 입력하는 것으로 갈음한다(재일 2012-1 87조 2항).

다만 채권과 그 밖의 재산권에 대한 압류명령, 추심명령, 전부명령, 관리명령, 양도명령 등은 채무자 및 제3채무자에게 송달하여야 하고 부동산 강제경매개시결정, 강제관리개시결정은 채무자에게 송달하여야 한다. 이에 관하여는 뒤에서 설명한다. 51

(2) 외국송달의 특례

집행법원은 집행절차에서 외국으로 송달이나 통지를 하는 경우에는 송달이나 통지와 함께 대한민국 안에 송달이나 통지를 받을 장소와 영수인을 정하여 상당한 기간 이내에 신고하도록 명할 수 있고(민집 13조 1항), 그 기간 이내에 신고가 없는 경우에는 그 이후의 송달이나 통지를 하지 아니할 수 있다(민집 13조 2항).

외국에 보내는 최초의 송달서류에는 대한민국 안에 송달이나 통지를 받을 장소와 영수인을 정하여 일정한 기간 안에 신고하도록 명함과 아울러 그 기간 안에 신고가 없는 경우에는 그 이후의 송달이나 통지를 하지 아니할 수 있다는 취지를 적어야 한다(민집규 10조).

(3) 신고의무

집행에 관하여 법원에 신청이나 신고를 한 사람 또는 법원으로부터 서류를 송달받은 사람이 송달받을 장소를 바꾼 때에는 그 취지를 법원에 바로 신고하여야 한다(민집 14조 1항). 그 신고를 하지 아니하고 달리 송달할 장소를 알 수 없는 경우에는 그 사람에 대한 송달은 법원에 신고된 장소 또는 종전에 송달을 받던 장소에 등기우편의 방법으로 발송할 수 있고, 이 경우 발송한 때에 송달된 것으로 본다(민집 14조 2항, 3항, 민집규 9조). 한편 민사집행법 14조는 집행절차에 관하여 적용되는 규정으로서 보전처분에 대한 제소명령절차는 집행에 관한 절차가 아니므로, 제소명령의 송달에 관하여는 민사집행법 14조가 적용될 여지가 없다(대결 2005. 8. 2. 2005마201).

52 다. 불복신청

민사집행절차에 관한 집행법원의 재판에 관한 불복방법으로는 즉시항고와 집행에 관한 이의신청이 있다. 전자는 법에 즉시항고를 할 수 있다는 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 할 수 있고(민집 15조 1항), 민사집행절차에 관한 집행법원의 재판으로서 그와 같은 규정이 없는 것에 대하여는 집행에 관한 이의신청에 의하여 불복할 수 있다(민집 16조).

4. 최고와 통지의 방법

가. 최고

집행법원이 행하는 집행절차에서 이해관계인에 대하여 일정한 행위를 하도록 촉구하는 최고가 필요한 경우가 있는데, 법은 경우에 따라 집행법원의 이름으로 최고하게 하거나(민집 253조) 집행법원의 법원사무관등이 자신의 이름으로 최고하게 하고 있다(민집 84조 4항).

민사집행절차에서 최고는 특별한 규정이 없으면 상당하다고 인정되는 방법으로 할 수 있고(민집규 8조 1항), 최고를 한 때에 법원사무관등은 그 취지와 최고의 방법을 기록에 표시하여야 한다(민집규 8조 2항). 상당하다고 인정되는 방법으로는 전화, 팩시밀리, 말에 의한 전달 등이 있으며, 보통우편과 엽서의 방법은 최고의 도달 여부를 확인할 수 없으므로 허용되지 않는다고 할 것이다.

최고를 받을 사람이 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 최고할 사항을 공고하면 되고, 이 경우 최고는 공고를 한 날부터 1주일이 지나면 효력이 생긴다(민집규 8조 3항). 있는 곳이 분명하지 아니한 때란 최고를 받을 사람의 주소·거소·영업소·사무소 또는 근무장소를 알 수 없는 경우를 의미하는 것으로서 공시송달의 요건 중 전단 부분과 동일하다. 외국에 있는 때란 외국에서의 소재가 알려져 있는 경우와 그렇지 아니한 경우 모두를 포함한다. 위 요건에 해당하는 경우에는 최고할 사항을 공고하면 되는데, 그 공고 절차에 관하여는 민사집행규칙 11조가 적용되므로 법원게시판 게시, 관보·공보 또는 신문 게재, 전자통신매체를 이용한 공고 중 어느 하나의 방법으로 한다. 공고의 방법에 의한 최고는 공고를 한 날부터 1주일이 지나면 효력이 생기는데, 집행절차의 신속성을 도모하기 위하여 공시송달의 경우보다 효력이 빨리 생기게 하고 있다.

나. 통지

민사집행절차에서 집행법원은 당사자, 그 밖의 관계인에 대한 통지를 법원사무관등 또는 집행관에게 그 이름으로 하게 할 수 있다. 다만 민사집행법 102조 1항에 규정된 통지, 즉 강제경매절차에서 남은 가망이 없을 경우에 집행법원이 압류채권자에게 하는 통지는 반드시 집행법원의 이름으로 하여야 한다(민집규 8조 5항).

민사집행절차에서 통지는 특별한 규정이 없으면 상당하다고 인정되는 방법으로 할 수 있고(민집규 8조 1항), 통지를 한 때에 법원사무관등은 그 취지와 통지의 방법을 기록에 표시하여야 한다(민집규 8조 2항). 상당하다고 인정되는 방법으로 전화, 팩시밀리, 말에 의한 전달 등이 있음은 최고의 경우와 같다.

채무자가 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 집행행위에 속한 송달이나 통지는 하지 아니하여도 된다(민집 12조). 집행의 신속을 기하여 채권자의 이익을 도모하기 위한 제도란 점, 강제집행개시의 요건에 해당하는 집행권원·집행문의 송달(민집 39조)이나 집행행위에 해당하는 재판(예를 들어, 강제경매개시결정, 채권압류 및 전부명령)을 고지하는 방법으로 하는 송달은 여기서 말하는 집행행위에 속한 송달에 포함되지 아니하므로 일반의 규정에 따라서 반드시 송달하여야 한다는 점 등은 집행관의 최고와 통지 부분에서 본 바와 같다.

또한, 민사집행법에 규정된 통지를 제외하고 민사집행규칙에서 정한 통지의 경우(민집규 23조 2항, 126조 1항, 127조 2항, 193조)에는 통지를 받을 사람이 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 통지를 하지 아니하여도 되고, 이 경우 법원사무관등은 그 사유를 기록에 표시하여야 한다(민집규 8조 4항).

5. 사법보좌관제도

54

가. 의의

2005. 3. 24. 법률 제7402호로 법원조직법 54조를 개정하면서 사법보좌관제도를 도입하여 2005. 7. 1.부터 시행하고 있다. 법원조직법 54조는, 대법원과 각급 법원에 사법보좌관을 둘 수 있고(1항), 사법보좌관은 민사소송법, 민사집행법 등에 규정된 법원의 사무 중 대법원규칙이 정하는 업무를 할 수 있으며(2항), 사법보좌관은 법관의 감독을 받아 업무를 수행하며 사법보좌관의 처분에 대해서는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 법관에게

이의신청을 할 수 있고(3항), 사법보좌관은 법원사무관 또는 등기사무관 이상 직급으로 5년 이상 근무한 사람, 법원주사보 또는 등기주사보 이상 직급으로 10년 이상 근무한 사람 중 대법원규칙으로 정하는 사람으로 하며(4항), 사법보좌관의 직제 및 인원과 그 밖에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정하는 것으로(5항) 규정하고 있다. 그리고 사법보좌관규칙은 법원조직법 54조의 규정에 따라 사법보좌관이 할 수 있는 업무의 범위, 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청, 업무의 감독, 사법보좌관의 자격 및 선발, 직제, 교육 그 밖에 필요한 사항을 정하고 있다.

사법보좌관은 법률과 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 법원의 업무 중 실질적 쟁송에 해당하지 아니하는 업무와 공증적 성격의 업무를 담당하는 일종의 사법관이다.

사법보좌관제도가 도입됨으로써 종전에 판사가 수행하던 대부분의 집행법원의 사무는 사법보좌관이 처리하고 있고, 이에 따라 집행절차에 있어서의 불복방법 중 즉시항고 등에 많은 변화가 일어나게 되었다(후술하는 즉시항고, 집행에 관한 이의신청 부분 등 참조).

나. 사법보좌관의 업무

55 (1) 사법보좌관이 행할 수 있는 업무는 법원조직법 54조 2항, 사법보좌관규칙 2조 1항에서 규정하고 있다. 그 중 민사집행절차에 관한 것은 다음과 같다.

- ① 집행문부여 명령(민집 32조, 35조, 57조)에 관한 법원의 사무
- ② 채무불이행자명부 등재절차(민집 70조 ~ 73조)에서의 법원의 사무
- ③ 재산조회절차(민집 74조, 75조 1항)에서의 법원의 사무
- ④ 부동산에 대한 강제경매절차(민집 78조 ~ 162조)와 자동차·건설기계·소형선박에 대한 강제경매절차(민집 187조)에서의 법원의 사무[다만 경매개시결정에 대한 이의신청에 대한 재판(민집 86조)에 해당하는 사무는 제외]
- ⑤ 유체동산에 대한 강제집행절차 중 압류물의 인도명령(민집 193조)과 특별현금화명령(민집 214조) 및 매각실시명령(민집 216조)에 관한 법원의 사무
- ⑥ 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행절차(민집 223조 ~ 251조)에서의 법원의 사무[다만 ㉗ 채권추심액의 제한허가(민집 232조 1항 단서), ㉘ 압류금지채권의 범위변경(민집 246조 2항 ~ 4항)에 해당하는 사무는 제외]
- ⑦ 동산에 대한 강제집행절차 중 배당절차(민집 252조 ~ 256조)에 관한 법원의 사무
- ⑧ 물건인도청구의 강제집행절차(민집 258조, 259조)에서의 법원의 사무
- ⑨ 부동산을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매절차(민집 264조 ~ 268조)와

자동차·건설기계·소형선박을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매절차(민집 270조)에서의 법원의 사무(다만 민집 86조의 규정이 준용되는 사무는 제외)

⑩ 유체동산, 채권과 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권의 실행절차(민집 271조 ~ 273조)에 관한 법원의 사무 가운데 민사집행법 193조, 214조, 216조, 223조 내지 251조, 252조 내지 256조의 규정이 준용되는 사무(다만 민집 232조 1항 단서, 246조 2항 ~ 4항의 규정이 준용되는 사무는 제외)

⑪ 유치권 등에 의한 경매절차(민집 274조)에서의 법원의 사무 가운데 민사집행법 264조 내지 268조, 270조, 271조 내지 273조의 규정이 준용되는 사무(다만 민집 86조, 136조, 232조 1항 단서, 246조 2항 ~ 4항의 규정이 준용되는 사무는 제외)

⑫ 부동산에 대한 강제경매절차 등 아래와 같은 집행절차에서의 법원의 사무 가운데 집행의 정지 및 제한(민집 49조), 집행처분의 취소 및 일시유지(민집 50조), 채무자 유산에 대한 강제집행을 위한 특별대리인의 선임 및 개임(민집 52조 2항, 3항), 군인·군무원에 대한 강제집행의 촉탁(민집 54조), 경매절차의 정지 및 경매절차의 취소·일시유지(민집 266조, 270조, 272조, 274조 1항) : 부동산에 대한 강제경매절차, 자동차·건설기계·소형선박에 대한 강제경매절차, 유체동산에 대한 강제경매절차, 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행절차, 물건인도청구의 강제집행절차, 부동산을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매절차, 자동차·건설기계·소형선박을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매절차, 유체동산·채권과 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권의 실행절차, 유치권 등에 의한 경매절차

56

⑬ 본안의 제소명령(민집 287조 1항, 301조, 가소 63조)

⑭ 가압류·가처분집행의 취소에 관한 법원의 사무[민사집행법 309조 1항의 '집행한 처분의 취소'는 가처분결정에 대한 이의신청이 있는 경우에 행하는 잠정처분으로서의 성격을 가지므로 사법보좌관의 업무에 속하지 않고, 현재로서는 해방공탁으로 인한 가압류집행의 취소만이 사법보좌관의 업무에 속한다. 한편 채권자가 집행취소(해제)신청을 한 경우나 채무자 등이 민사집행법 49조, 50조의 집행취소서류를 제출한 경우의 말소촉탁 등 집행취소사무는 민사집행법 제정 당시 법원사무관등의 업무로 조정되었으므로, 이러한 사무도 사법보좌관의 업무가 아니다]

(2) 사법보좌관은 주로 경매 등 민사집행절차에서 실질적 쟁송에 해당하지 않는 비송적 업무와 집행문부여절차와 같은 공증적 성격의 업무 중 법률과 대법원규칙이 위임하는 일부를 처리하고, 당사자 사이에 다툼이 있는 실질적 쟁송사건인 민·형사상의 일반 사건

- 은 담당하지 않는다. 그리하여 경매절차 가운데에서도 채권추심액의 제한하가 등은 사법보좌관의 업무에서 제외하였고, 경매개시결정에 대한 이의신청 재판은 경매개시결정에 대한 불복절차이므로 당연히 제외하였다. 그리고 가압류·가처분절차 및 그 불복절차는 민사
- 57 집행법에서 규정하고 있지만, 집행권원이 없는 상태에서 임시로 채무자의 재산을 동결하는 조치를 하는 절차로서 피보전권리의 존부 및 보전의 필요성에 대한 실체적 판단이 필요한 실질적 쟁송에 해당하므로, 사법보좌관의 업무에서 제외하였다. 다만 가압류집행의 취소는 쟁송성이 없으므로 사법보좌관의 업무로 하였다.

제5절 수소법원

1. 의의

수소법원이란 집행에 의하여 실현될 청구권의 존부를 확정하고 집행권원을 형성하는 절차에 관하여 관할이 있거나 또는 그러한 소송이 계속(係屬)하여 있거나 전에 계속하였던 법원을 말한다. 판결절차와 집행절차를 분리하고 있는 현행법하에서는 수소법원이 집행기관으로 되는 것은 예외이나, 아래에서 보는 바와 같이 제1심 수소법원이 집행기관 또는 집행공조기관이 되는 경우가 있다.

2. 직무관할

가. 집행기관으로서 행하는 것

청구의 내용과 관련하여 구체적인 집행방법을 판정하는 것이 필요한 경우로서 ① 대체 집행(민집 260조, 민 389조)과 ② 간접강제(민집 261조)는 제1심 수소법원이 관할한다.

나. 집행공조기관으로서 행하는 것

- 외국에서 강제집행을 할 경우에 그 외국 공공기관의 법률상 공조를 받을 수 있는 때 또는 외국에 머물고 있는 대한민국 영사에 의하여 강제집행을 할 수 있는 때에는 제1심
- 58 수소법원이 채권자의 신청에 따라 공조 또는 강제집행을 촉탁한다(민집 55조).

3. 수소법원의 재판

수소법원의 집행에 관한 행위도 모두 결정의 형식에 의한 재판으로 한다. 변론을 거칠 필요는 없지만, 대체집행과 간접강제에 관한 재판을 할 경우에는 미리 채무자를 심문하여야 한다(민집 262조). 위 각 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 260조 3항, 261조 2항).

제6절 그 밖의 집행기관

1. 등기관

부동산에 대한 가압류의 집행에 관하여는 등기관이 집행기관이 된다. 위 집행은 법원의 촉탁에 의하여 가압류의 재판을 등기기록에 기입하는 것이 그 집행방법이므로(민집 293조), 위 기입을 실시하는 등기관이 집행기관이 되는 것이다. 처분(양도나 저당 등) 금지의 가처분에 관하여서도 같다(민집 305조 3항). 그러나 등기를 명하는 판결에 기하여 등기기록에 기입하는 것은 그것이 비록 광의의 집행이기는 하지만 고유의 집행은 아니므로 이 경우의 등기관은 집행기관이 아니다.

2. 공조기관

집행사건에서 집행기관은 아니나 법률, 조약 등에 의하여 집행에 협력하는 공무소 또는 공무원이 있는데, 이를 공조기관이라 한다. 예를 들어, 수소법원의 법원사무관등(민집 28조 2항), 공증인(민집 59조 1항), 경찰관(민집 5조 2항, 6조), 국군(민집 5조), 지방공무원(민집 6조), 군판사 또는 부대장(部隊長)이나 선장(민집 54조 1항), 외국 공공기관 및 외국 주재의 대한민국 영사(민집 55조) 등이다.

제4장 민사집행 전자소송

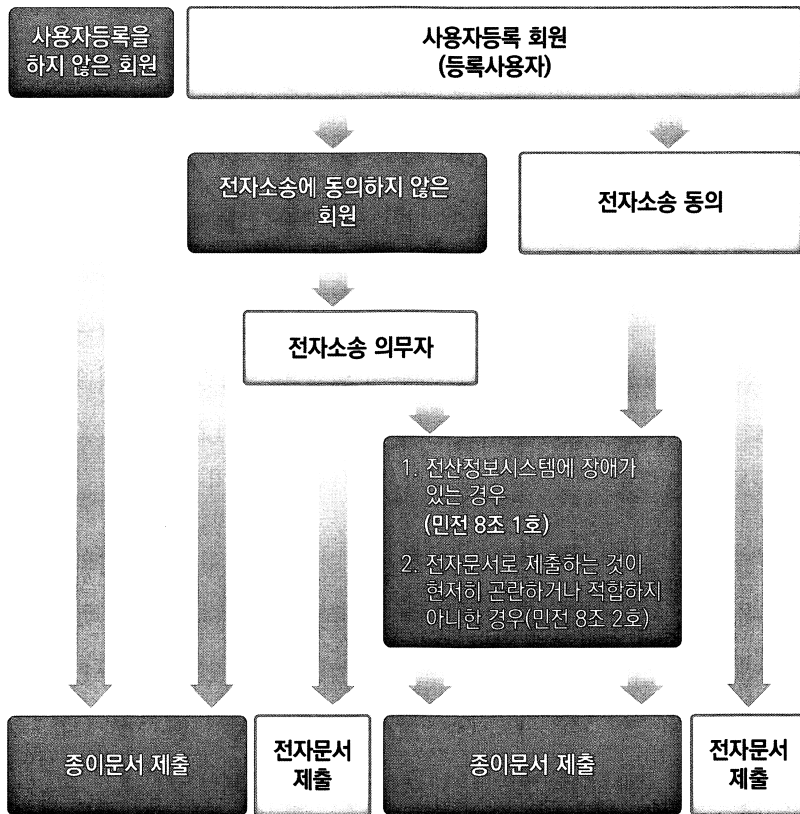
1. 총설

민사집행 전자소송(이하 ‘전자소송’)은 민사집행절차에서 전자소송시스템을 이용하여 각종 신청서와 재판서 등을 작성, 제출, 관리, 송달, 열람, 보존하는 일련의 과정을 의미한다.

채권자등 이해관계인(이하 ‘채권자등’)은 전자소송시스템이 구현되어 있는 전자소송홈페이지를 이용하여 문서를 전자적으로 제출할 수 있고, 법원은 재판사무시스템을 이용하여 사건기록을 전자적으로 관리할 수 있다.

다만 전자소송은 국가나 지방자치단체, 그 밖에 규칙에서 정하는 행정청이나 공공기관 등 전자문서 제출 의무를 부담하는 전자소송의무자를 제외하고, 채권자등의 동의를 전제로 진행되기 때문에 채권자등은 사전에 전자소송홈페이지에서 사용자등록 및 전자소송으로의 진행에 동의하는 절차를 밟아야 한다.

2010. 3. 24. 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률이 공포·시행됨에 따라 전자소송의 규범적 기반이 마련되었고, 2010. 4. 26. 특허소송을 시작으로 2015. 3. 23. 민사집행·비송사건에서도 전자소송이 실시되었다. 전자소송 절차에 관한 세부내용에 대하여는 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙과 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 업무처리지침(재일 2012-1)에서 규율하고 있다.



2. 전자소송 준비

채권자등이 집행법원에 제출하는 문서는 ① 부동산경매신청서 등 새로운 사건을 생성하는 성격의 문서와, ② 이미 진행 중인 사건에 배당요구 등의 목적으로 제출하는 문서로 대별할 수 있다.

채권자등이 위와 같은 문서를 전자적 형태로 제출하기 위해서는 전자소송홈페이지에 접속하여 사용자등록과 전자소송 동의를 하여야 한다. 위 ②의 문서는 각종 결정문이나 최고서와 함께 송달되는 전자소송안내서[전산양식 A6003]에 기재되어 있는 해당 사건의 전자소송인증번호를 입력한 후 전자문서로 제출할 수 있다.

가. 사용자등록

채권자등이 집행법원에 전자문서를 제출하기 위해서는 사용자등록을 하여야 한다(민전 6조 1항).

사용자등록을 할 수 있는 회원의 종류는 개인회원, 법인회원, 변호사회원, 법무사회원, 회생·파산사건의 절차관계인회원, 집행관등(관리인, 감수·보존인 포함)이 있다.

사용자등록을 한 법무사는 전자문서를 작성·제출할 수 있지만 법무사법 2조에 의하여 서류의 작성 및 제출대행 등의 업무만 할 수 있으므로 전자문서 제출 시마다 제출위임인의 확인서와 제출위임장을 함께 제출하여야 한다.

집행법원으로부터 문서송부촉탁과 사실조회촉탁을 받은 자(민전규 3조 7호)는 물론이고, 외국인이나 주민등록번호가 없는 재외국민도 개인회원으로서 외국인등록번호나 공인인증서 발급 신청 시 사용한 성명 및 공인인증서 발급 대행기관으로부터 부여받은 식별번호를 입력하는 방법으로 사용자등록을 할 수 있다(재일 2012-1 9조).

사용자등록을 할 때에는 전자소송시스템이 요구하는 사용자정보를 입력해야 한다(재일 2012-1 7조). 특히 휴대전화번호와 전자우편주소 등은 전자적 송달을 위하여 필수적인 정보이므로, 변경된 때에는 전자소송시스템을 통하여 변경된 정보를 입력해야 한다(재일 2012-1 8조). 이를 수정입력하지 아니하여 종전의 휴대전화번호로 문자메세지가 전송되거나 전자우편주소로 전자우편이 전송되더라도 그 전송된 때에 통지의 효력이 인정된다(민전규 26조 2항).

사용자등록을 한 자(단 개인회원은 제외)는 이용권한의 범위를 정하여 소속사용자를 지정할 수 있고, 그에 따라 지정된 자는 전자소송시스템에 소속사용자로 등록할 수 있다(민전규 4조 2항).

- 62 사용자등록을 한 자(이하 ‘등록사용자’)는 전자소송시스템에 접속하여 사용자등록을 철회할 수 있는데, 전자소송 동의를 한 등록사용자는 계속 중인 사건이 있으면 재판장 등의 허가를 받아야 한다(민전규 5조, 10조 2항).

법원행정처장은 등록사용자의 동일성이 인정되지 않는 경우, 사용자등록을 신청하거나 사용자정보를 변경할 때 거짓 내용을 입력하는 등의 경우 등록사용자의 사용을 정지하거나 사용자등록을 말소할 수 있다.(민전 6조 3항, 민전규 6조 1항).

나. 전자소송 동의

전자소송 동의는 서류의 전자적 제출과 송달 등 전자적 절차진행에 대해 동의하는 것이다. 전자소송 동의를 한 당사자는 전산정보처리시스템에 장애가 있거나 전자문서로 제출하는 것이 현저히 곤란하거나 적합하지 아니한 경우가 아니면 반드시 전자문서로 제출하여야 한다(민전 8조). 따라서 전자문서가 아닌 서류를 법원에 제출하고자 할 때에는 그

서류를 전자문서로 변환하여 제출하여야 하고 이에 따르지 아니하는 경우 그 서류는 원칙적으로 제출되지 아니한 것으로 본다(민전규 12조 1항, 2항 본문).

법원은 전자소송 동의를 한 당사자에게 전자적 송달을 할 수 있으므로(민전 11조 1항), 그 당사자는 전자소송시스템에 접속하여 송달한 서류를 확인할 의무를 부담한다(민전 11조 4항 참조).

전자소송 동의는 등록사용자별로 하여야 하고 그에 대하여만 효력이 있다(재일 2012-1 13조 1항, 14조 1항). 따라서 전자소송 동의를 한 채권자등만이 전자적 열람을 할 수 있고, 전자소송 동의를 하지 아니한 채권자등은 전자적 열람을 할 수 없다(민전규 38조 1항).

전자소송 동의는 그 법적 성격을 일종의 소송행위로 볼 수 있는데, 그 동의가 유효하기 위해서는 소송능력이 요구되고, 절차적 안정을 위하여 동의를 철회하거나 그 철회를 취소하기 위해서는 재판장 등의 허가를 받아야 한다(민전규 10조 2항).

전자소송 동의의 유형(민전 11조 1항)은 사전동의(1호), 사후동의(2호), 전자소송의무자 63 (등록사용자가 국가, 지방자치단체, 그 밖에 그에 준하는 자로서 대법원규칙으로 정하는 자인 경우)로서 동의가 불필요한 경우(3호)가 있는데, 사전동의는 사전에 개별사건에 대하여 하는 사전개별동의(민전규 24조 1항 1호)와 각종 신청이 빈번한 금융기관 등이 1년의 기간 범위에서 일정한 기간을 정하여 그 동안에 자신이 당사자 등이 될 경우에 전자소송 동의의 효력을 부여하는 사전포괄동의로 구분된다. 사전포괄동의자나 전자소송의무자는 개별 사건에서 전자소송 동의가 없더라도 사용자등록만 되어 있으면 서류의 전자적 제출·송달·열람 등이 가능하다.

채권자등 이해관계인 중에서 일부만이 전자소송 동의를 하거나 전자소송의무자인 경우 나머지에 대해서는 종이소송을 하게 되는데, 이 경우 종이서류의 전자문서 변환업무(민전 10조 2항)와 전자문서의 출력송달업무 등이 수반되므로 이러한 노력과 비용을 최소화하기 위하여 가능한 한 모두 전자소송으로 유도할 필요가 있다.

전자소송 동의는 당해 사건이 확정될 때까지 효력이 있고, 본안사건에 관한 동의는 그에 부수하는 신청사건에 미치는데, 재판장 등의 허가가 있으면 전자소송 동의를 철회하거나 그 철회를 취소할 수도 있다(민전규 10조). 전자소송 동의뿐만 아니라 철회도 등록사용자별로 하여야 하고, 그 효력은 해당 사용자에게만 미친다.

한편 민사집행법 161조에 따라 공탁금에 대한 배당을 실시하는 경우 종전의 전자소송 동의는 재배당 및 추가배당 절차에 그 효력이 없다(재일 2012-1 13조, 14조).

다. 전자소송인증번호의 부여와 사용

다른 채권자등에 의해 이미 진행 중인 전자사건에서 전자문서를 제출하기 위해서는 전자소송인증번호가 필요하다.

- 64 민사집행법의 적용을 받는 일정한 사건의 경우 법원사무관등이 전자소송 동의를 방식과 전자소송인증번호 등이 기재된 전자소송안내서[전산양식 A6003]를 함께 보내도록 되어 있다(재일 2012-1 60조 3호). 결정이나 최고서 등에 첨부된 전자소송안내서를 수령한 채권자등은 공인인증서를 준비하여 전자소송홈페이지에서 사용자등록과 전자소송 동의를 한 후 전자소송인증번호를 입력하면 당해 사건에서 전자문서를 제출할 수 있게 된다. 일단 전자소송인증번호를 입력하면 그 사건관계인의 [나의 사건관리]의 [진행 중 사건] 목록에 그 사건이 등재되므로 그 이후부터는 전자소송인증번호 입력을 요하지 않는다.

한편 사전포괄동의자나 전자소송의무자는 전자소송 동의가 없어도 전자적 송달과 전자적 제출이 가능하므로 원칙적으로 전자소송인증번호가 필요 없다.

3. 전자문서의 접수

전자소송 시행 이후의 접수업무는 전자접수와 종이접수로 대별되고, 다시 각 사건접수와 문건접수로 구분할 수 있다. 전자기록사건임에도 종이기록사건으로 잘못 전산입력하거나 그 반대의 경우에는 [ECM431. 전자소송정보 처리]에서 소송구분을 변경하면 된다.

가. 사건접수

(1) 전자접수

신청서 등이 전자적으로 접수되면 사건번호가 자동으로 부여되고, 접수사무관등이 재판사무시스템상 [ERC100. 전자접수확인]에서 문서뷰어를 통해 신청서를 심사하고 배당한 뒤 [신청서접수확인]을 하게 되면 기록은 전자적으로 담당 재판부로 인계된다. 이때 접수사무관등은 신청서에 대한 심사결과를 신청서 심사체크리스트에 전자적으로 표시하여 담당 재판부로 인계하여야 한다(재일 2012-1 18조 1항).

- 65 전자기록사건이 항고나 이송 등의 사유로 송부된 경우 접수사무관등이 재판사무시스템상 [ERC300. 송부기록인수확인]을 하고 사건접수(이때 [전자사건번호부여부]로 들어가서 별도로 사건번호를 부여하여야 한다)를 하여야 배당담당자에게 인계되고, 반환기록은 접

수사무관등이 기록인수확인을 하면 자동으로 반환영수일이 입력되어 해당 재판부로 인계된다.

(2) 종이접수

접수사무관등은 종이로 된 신청서가 제출된 경우 신청채권자, 채무자(소유자) 또는 규칙 3조 1호부터 4호까지 정한 자가 전자소송의무자 또는 사전포괄동의자에 해당하는지 여부를 확인하여야 한다(재일 2012-1 17조 1항). 이는 [ECM411. 전자소송대상자조회]를 통해 확인할 수 있다. 위의 경우에 해당한다면 종이로 신청서를 제출할 정당한 사유가 있는지 여부에 관하여 심사한 후 정당한 사유가 없는 경우에는 신청서를 전자적으로 제출할 것을 촉구한다(재일 2012-1 17조 2항). 신청인이 사전포괄동의자이거나 전자소송의무자임에도 불구하고 착오로 종이기록사건으로 접수한 후에 이와 같은 사실을 발견한 경우 실무상 위 신청을 취하한 후 전자소송 절차를 밟도록 권고하기도 한다.

나. 문건접수

(1) 전자기록사건

전자기록사건에서 전자문서가 제출되면 접수사무관등을 거치지 않고 전자기록에 자동으로 편철되고 법원사무관등의 [ECA311. 문건/결재캐비닛]으로 들어온다. 문건의 전자적 제출은 24시간 가능하므로 긴급을 요하는 중요서류가 접수되었는지 법원사무관등은 수시로 확인하여야 한다. 집행정지·취소신청 등 중요서류가 접수된 경우 [MG101. 문건 입력/수정]의 환경설정에서 알리미가 전송되도록 설정할 수 있다.

전자소송 동의를 한 자는 ‘전자소송시스템 등을 이용할 수 없는 경우(민전규 14조)’와 ‘전자문서화가 곤란하거나 부적합한 경우(민전규 15조)’에 해당하는 사유가 없는 한 원칙적으로 전자문서로 제출하여야 하고(민전 8조, 민전규 12조 1항) 이에 위반한 경우 그 서류는 제출되지 아니한 것으로 본다(민전규 12조 2항). 접수사무관등은 전자소송 동의를 한 자가 종이문건을 제출하면서 정당한 사유에 해당한다고 인정할만한 소명자료가 없거나 불충분한 경우, 전자문서로 제출하도록 하거나 정당한 사유를 소명할 자료를 추가 제출하도록 권고한다. 특히 제출기한이 정해진 즉시항고장 등의 경우에는 그 기한이 경과하지 않도록 유의하여야 한다.

전자소송 동의를 하지 않은 당사자는 전자기록사건에서도 종이서류를 제출할 수 있으며 접수사무관등은 재판사무시스템에 제출된 서류의 제출자, 접수일시, 문건명 등을 입력한

후 이를 전자문서로 변환한다(재일 2012-1 19조 3항). 이때 전자문서를 출력한 서면이 제출된 경우에는 예외적으로 그 서면을 전자화하지 않고 제출당사자로부터 해당 전자문서를 자기디스크 등에 담아 제출받거나 전자우편으로 전달받아 이를 등재하는 방법도 가능하다(민전규 19조 2항).

접수사무관등은 전자문서가 아닌 형태로 제출된 서류를 전자문서로 변환하고 제출자에게 그 동일성을 확인할 기회를 준 후(민전규 17조 2항) 전자기록에 대한 동일성 확인서[전산양식 A6103]를 받고 종이서류는 제출자에게 반환한다. 반환절차를 밟기가 어려운 경우에는 일정기간 동안 전자화문서와의 동일성에 대하여 이의를 제기하지 않으면 해당 문서를 폐기할 수 있다는 것을 고지하여야 한다. 대상문건이 원본인 경우에는 민사보관물 관리에 관한 예규(재민 79-7)에 따라 처리한다(재일 2012-1 19조 6항).

실무상 전자화가 끝난 종이서류는 보존담당부서로 인계하여 전자화 일자가 속한 월의 말일로부터 12월간 가보존한 후 폐기하고 있다(재일 2012-1 31조 6항 참조).

(2) 종이기록사건

- 67 기준시(신청서 제출 시 등)까지 전자소송 동의가 없어서 종이기록으로 진행되고 있는 사건에 대하여 채권자등이 사후적으로 전자소송 동의를 하게 되면 동의한 자에 한해서 전자문서 제출이 가능하다. 종이기록사건에서 전자적으로 제출된 문건은 법원사무관등의 [ECA311. 문건/결재캐비닛] 화면 중 [종이기록 전자접수 문건]에서 즉시 확인이 가능하다. 따라서 법원사무관등은 이를 출력하여 기록에 편철하여야 할 것이다.

2015. 3. 23. 민사집행 전자소송이 시행된 이후에 접수된 종이기록사건의 경우에도 전자적 형태로 문서 제출이 가능하고, 이 경우 접수인의 표시를 생략할 수 있다(재일 2012-1 20조 4항).

4. 전자기록화

가. 대상

전자기록화란 전자문서가 아닌 형태로 제출된 서류를 전자문서로 변환하고, 사법전자서명을 하여 전산정보처리시스템에 등재함으로써 전자기록을 조제하는 작업(재일 2012-1 2조 2호 및 3호)을 의미하는데, 전자기록화로 인하여 기록의 전자적 관리 및 전자적 송달·열람·보존 등이 가능하다.

법원이 작성하는 민사소송 등의 모든 재판서와 조서 등은 원칙적으로 전자문서로 작성하여야 하고 종이문서로 작성한 경우에는 이를 전자문서로 변환하여 전산정보처리시스템에 등재하여야 한다(민전 10조 1항).

법원사무관등은 대법원규칙에서 정하는 사유가 없으면 전자문서가 아닌 형태로 제출된 서류를 전자문서로 변환하고 전산정보처리시스템에 등재하여야 한다(민전 10조 2항). 즉 상소심 사건의 원심사건이 전자기록사건이 아닌 경우(민전규 19조 1항 1호), 재심 또는 준재심 사건의 대상사건이 전자기록사건이 아닌 경우(2호), 기본이 되는 본안사건 또는 신청사건이 전자기록사건이 아닌 경우 그에 부수하는 신청사건(단, 보전처분 신청사건은 본안사건의 전자기록화 여부에 따르지 아니한다)(3호), 그 밖에 법원행정처장이 전자기록화의 대상이 아닌 사건으로 정하여 전자소송홈페이지에 공고한 사건(4호)에 해당하지 않는 한 전자기록화 대상이 된다. 전자기록화의 대상이 아닌 사건으로 정하여 전자소송홈페이지에 공고한 사건(4호)은 채권자등이 일정 시점까지 전자소송 동의를 하지 아니한 사건 등을 말한다(재일 2012-1 27조 1항 각 호). 다만 이 경우에도 재판장등은 사건기록의 전자문서화를 명할 수 있다(민전규 19조 1항 단서).

68

전자기록화 대상은 ① 전자기록사건에서 전자소송 동의를 하지 아니한 채권자등이 제출한 서류, ② 전자기록사건에서 예외사유에 해당되어 적법하게 제출된 종이서류, ③ 종이기록사건에서 당사자의 전자소송 동의 또는 재판장등의 전환명령에 의하여 전자기록사건이 된 경우에 그 당시까지 제출된 모든 서류, ④ 민사집행법 237조 1항의 제3채무자 진술서 등, ⑤ 종이기록사건에서 상대방이 전자소송의무자나 사전포괄동의자인 경우 제출된 종이서류 등을 들 수 있다(재일 2012-1 28조 1항 등).

위 ③과 관련하여 부동산경매사건에 압류의 경합이 있는 경우에 후행 사건의 전자기록화는 먼저 경매개시결정을 한 사건의 신청서 제출 시까지 채권자등의 전자소송 동의가 있어야 한다(재일 2012-1 27조 1항 1호 사목).

기타 집행사건 중 「민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규(재민 91-1)」 3조 1항 별표상의 별도기록 편철 사건 및 민사집행법에 따른 재산조회 및 채무불이행자명부 등재 사건 등은 전자소송 동의 여부와 무관하게 전자기록사건으로 한다(재일 2012-1 27조 2항, 3항).

나. 절차

접수담당자가 전자화 대상 문건을 입력한 후 전자화요청서를 출력하여 전자화할 서류와

함께 전자화담당자에게 전달하여 스캔을 하게 되면 스캔문서는 경매계 등 법원사무관등의 [ECA311. 문건/결재캐비닛]으로 이동하고, 법원사무관등이 [문건분류]와 [스캔확인]을 하게 되면 전자화 작업이 종료된다. 종이서류를 스캔한다고 하여 전자기록에 바로 편입되는 것이 아니라 [스캔확인]까지 완료해야 비로소 당해 서류가 전자기록에 편입된다. 따라서
69 법원사무관등은 [ECA311. 문건/결재캐비닛]에 전자화대상 문건이 남아있는지 여부를 수시로 확인할 필요가 있다.

소급적 전자화 사건이나 법정제출 문서의 경우에는 법원사무관등이 모든 공정을 처리하여야 하는데, 소급적 전자화 사건은 [소급적 전자기록화 대상 사건목록]에서 그 대상사건을 확인하여야 전자사건기록이 생성된다.

전자기록화 과정 중에 오류나 수정할 부분이 발생한 경우 [예외사항 요청]과 [전자화 재요청]을 활용하여 이를 시정할 수 있다.

서적이나 도면 등 전자화불가문서(민전규 15조 1항)가 제출된 경우에도 전자기록화 요청을 하여야 하는데, 해당 서류 표지만 전자화하고, 나머지는 전자화불가문서로 처리한 후, 법원사무관등에게 인계하게 되면 법원사무관등은 기록표지를 출력하여 해당 문서를 편철하는 방법으로 관리한다(재일 2012-1 29조).

5. 전자적 송달·통지 등

가. 전자적 송달·통지

전자기록사건에서 새로이 전자문서가 등재된 경우 채권자등에게 이를 고지할 필요가 있는데, 전자정보처리시스템에 등재된 전자문서를 전자소송 동의를 한 자 또는 전자소송 의무자에게 그 등재사실을 전자우편과 휴대전화 문자메시지로 통지하는 방식(민전 11조 1항, 3항, 민전규 26조 1항)으로 전자적 송달을 실시한다. 이에 따라 통지를 받은 자는 전자소송시스템에 접속하여 등재된 전자문서를 확인 또는 출력할 수 있다(민전규 26조 4항). 사전포괄동의자나 전자소송의무자가 위와 같은 통지를 받기 위해서는 미리 사용자 등록을 하여야 한다(민전규 24조 1항 2호, 25조 2항).

법원의 통지에 따라 송달받을 자가 등재된 전자문서를 확인한 때 송달된 것으로 보지만 그 등재사실을 통지한 날부터 1주 이내에 확인하지 아니한 때에는 등재사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 본다(민전 11조 4항).
70

당사자와 소송대리인 등이 민사소송법 184조에 의하여 등록사용자를 송달영수인으로

신고한 경우에는 전자적 송달·통지는 그 송달영수인에게 하여야 한다(민전규 24조 1항 3호).

전자적 송달에 관한 규정(민전 11조 1항)은 임의규정이므로 우편송달도 가능한 것으로 해석되지만 전자소송으로 인한 당사자의 송달 및 열람의 편의를 위하여 우편송달이 불가피한 예외적인 경우 이외에는 전자적 송달을 우선적으로 실시하여야 할 것이다.

나. 전자적 열람

강제집행이 진행 중인 사건에 관하여 채권자등이나 이해관계를 소명한 제3자는 사건기록의 열람·복사를 신청할 수 있다(민집 23조 1항, 민소 162조 1항). 이들 중 전자소송 동의를 한 등록사용자로서 채권자등, 소송대리인, 법정대리인, 특별대리인 등은 전자소송 홈페이지에 접속하여 소송기록을 전자적으로 열람·출력 및 복제할 수 있다(민전규 38조 1항). 반면 그 신청인이 전자소송 동의를 하지 아니한 자인 경우에는 법원에 비치된 컴퓨터 단말기를 통하여 사건기록을 열람할 수 있고, 법원에 해당 사항의 복제 또는 출력물 교부를 요청할 수 있다(민전규 38조 2항).

한편 사용자등록을 한 법무사는 개별사건별로 당사자본인으로부터 전자기록 열람권을 위임받아 전자소송시스템을 이용하여 전자적 열람을 신청할 수 있다(민전규 38조 4항). 법원사무관등은 그 위임사실이 소명되는지 확인하고 열람을 허용하여야 하는데, 그 허가가 늦지 않도록 [ECM151. 전자열람신청서 조회]를 주기적으로 확인할 필요가 있다.

강제집행 등이 법원에 계속되는 동안에 전자기록을 열람·출력 또는 복제하는 경우(민전규 38조)에 신청인은 수수료를 납부하여야 하지만, ① 법원에서 제공되지 아니하는 컴퓨터를 이용하여 열람·출력 또는 복제하는 경우(민전규 39조 2항 1호)와 ② 신청인이 법원에서 제공되는 컴퓨터를 이용하여 열람을 하는 경우(민전규 39조 2항 2호), 각 수수료를 면제한다. 전자기록의 열람·출력 또는 복제에 관하여 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙에 특별한 규정이 없으면 재판기록 열람·복사 규칙을 준용한다(민전규 39조 3항).

다. 전자적 보존

전자기록사건도 종이사건과 동일하게 보존하기 전에 보관금 종결, 송달료 종결 등을 점검하여 잘못된 부분을 바로잡은 다음 완결공람 결재를 받아야 한다(재일 2012-1 103조).

기록완결공람이 끝난 후 기록인계일 작업을 완료하게 되면 기록캐비닛에서 보존할 기록이 보존담당부서로 전자적으로 인계된다.

이때 전자화되지 않은 문서가 있으면 해당 문서를 사건별, 제출된 시간 순서대로 정리하여 기록으로 조제한 후 보존담당부서에 전자기록의 인계와 동시에 송부한다(재일 2012-1 106조 1항, 2항).

상급심에서 확정되어 반환될 기록이 전자적으로 송부되어 접수담당자가 이를 확인하면 별도의 전자공람 없이 보존담당부서로 인계된다.

전자기록은 책수 및 질수 모두 '0'으로 입력하고 보존기간은 영구로 하여 보존등록을 한다(재일 2012-1 107조 참조).

라. 재판서 문서고유번호를 통한 당사자 동일성 확인

개인정보 보호를 위하여 당사자의 주민등록번호가 판결서 등 집행권원에 표시되지 않는 데(재일 2003-12 9조 1항 1호 참조), 집행법원은 당사자의 동일성 확인을 위하여 주민등록번호 등 개인정보가 필요한 경우에 판결서 등 집행권원 정보 하단에 기재된 문서고유번호를 이용할 수 있다. 즉 민사집행법에 따라 강제집행의 실시를 위하여 집행권원이나 그 집행력 있는 정본을 전자문서로 변환하여 제출하는 자는 법원이 그 집행권원 등에 부여한 문서고유번호를 전자소송시스템에 입력하여야 하고, 문서고유번호를 입력하지 못한 경우에는 제출하고자 한 집행권원 등의 원본을 제출하여야 한다(민전규 44조). 종이사건의 경우에도 문서고유번호가 있는 경우에는 사건접수 후 접수담당자가 위 고유번호를 재판사무시스템에 입력하여야 한다. 이에 따라 집행법원은 재판사무시스템 [MG209. 발급문서번호로 당사자 정보조회]나 코트넷 사건검색 화면의 [재판서발급번호로당사자조회]에서 재판서에 기재된 문서고유번호와 당사자의 개인정보를 확인할 수 있다.

한편 해당 사건이 종국되기 전에 전자소송에 동의한 당사자와 소송대리인은 전자소송시스템을 이용하여 제증명(이하 '인터넷 제증명') 신청을 할 수 있는데, ① 전산공증이 완료된 사건의 송달증명, 확정증명과 전자문서 접수와 동시에 발급되는 접수증명의 경우 (법원 사무관등의 관여 없이) 인터넷 자동발급이 가능하고, ② 민사본안사건에서 조건성취, 승계, 수통부여, 재도부여에 해당하지 않는 단순 집행문의 경우 (법원사무관등의 심사를 요하는) 수동발급으로 처리된다. 각급 법원에서는 인터넷 제증명의 발급담당자를 지정하여 운영하고 있다(재일 2007-1 16조 참조).